

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 법규명령은 행정 주체와 국민 사이의 법률관계를 규율하는 일반적·추상적 규범으로서, 국민에게 대외적 구속력을 가진다.

반면, 표준지공시지가 조사·평가 기준은 상위법령(부동산공시법 제3조 제4항 및 시행령 제6조 제3항)의 위임을 받아 법령을 보충하는 법령보충적 행정규칙으로서, 형식과 실질이 다르다. 이로 인해 표준지공시지가 조사·평가 기준의 대외적 구속력 여부가 문제된다. (35점)

물음1) 법령보충적 행정규칙의 의의 및 법적 성질을 논술하시오. (15점)

물음2) 법령보충적 행정규칙의 사법적 통제 수단에 대하여 논술하시오.(20점)

참고 조문
<표준지공시지가 조사·평가 기준> 제1조(목적) 이 기준은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에서 규정하고 있는 표준지 공시지가의 공시를 위하여 같은 법 제3조제4항 및 같은 법 시행령 제6조제3항에 따라 표준지의 적정 가격 조사·평가에 필요한 세부기준과 절차 등을 정함을 목적으로 한다. <헌법> 제107조 ②명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.

【문제 2】 택지조성사업을 하고자 하는 사업시행자 甲이 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 국토교통부장관은 택지면적의 60%를 택지와 실질적인 관련 없는 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 이에 甲은 해당 조건은 비용이 과다하여 사업성에 문제가 있다고 주장한다. (25점)

물음 1) 기부채납 조건이 **부당결부 금지의 원칙**에 반하는지 검토하시오. (10점)

물음 2) 기부채납 조건이 **비례의 원칙**에 반하는지 검토하시오. (15점)

참고 조문
<공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률>
제2조(정의)
7. “사업인정”이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.
제20조(사업인정)
① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

【문제 3】 대한민국 헌법 제11조에서는 '모든 국민은 법 앞에 평등하다'고 규정한다. 법의 일반원칙 중 ①**평등의 원칙**과 ②**자기구속의 원칙**에 대하여 각각 설명하시오. (20점)

【문제 4】 「감정평가법 시행령 별표3」은 법규명령의 형식을 취하고 있으나, 그 실질이 행정청 내부의 사무처리기준인 행정규칙이다. 이러한 **법규명령 형식의 행정규칙**의 법적 성질에 대하여 설명하시오. (10점)

【문제 5】 법의 일반 원칙 중 법적 안정성을 고려하는 **신뢰보호의 원칙**에 대하여 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 선결문제는 항고소송의 수소법원 이외의 다른 법원이 민사소송이나 형사소송에서 본안판단의 전제로서 행정행위의 위법 여부나 효력 여부에 관한 판단을 할 수 있는가의 문제를 의미한다(40점)

물음 1) 공정력에 대해 설명하고 구성요건적 효력과 구별논의를 서술하시오.(10점)

물음 2) 민사법원에서 행정행위의 위법성을 심사할 수 있는지 행정행위의 구성요건적 효력과 관련하여 서술하시오.(10점)

물음 3) 민사법원에서 행정행위의 효력 유무를 심사할 수 있는지 행정행위의 구성요건적 효력과 관련하여 설명하시오.(5점)

물음 4) 형사법원에서 행정행위의 위법성을 심사할 수 있는지 행정행위의 구성요건적 효력과 관련하여 설명하시오.(10점)

물음 5) 형사법원에서 행정행위의 효력 유무를 심사할 수 있는지 행정행위의 구성요건적 효력과 관련하여 설명하시오.(5점)

<참고조문>

[행정소송법] 제11조(선결문제)

① 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이 이를 심리·판단하는 경우에는 제17조, 제25조, 제26조 및 제33조의 규정을 준용한다.

【문제 2】 감정평가 수험생 甲은 2024년 감정평가 시험에 총점 차이 0.5점으로 불합격하였다. 이에 甲은 2023년까지 감정평가사를 200명으로 선발하였으나, 2024년에는 190명으로 선발하여 선발인원을 줄인 것은 평등의 원칙에 반하여 위법하다고 주장한다. 이에 국토교통부장관은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령」 제10조를 근거로, “감정평가관리·징계위원회가 감정평가 업무 현황, 자격증 보유자 현황, 수급동향 등을 종합적으로 검토하여 심의한 결과 결정한 것”이라며, 선발인원 축소에는 합리적인 이유가 있다고 밝혔다. (20점)

물음 1) 甲의 주장의 타당성을 검토하시오.(5점)

물음 2) [감정평가법 시행령] 제10조의 감정평가사 합격기준의 해석과 관련하여 판단여지의 개념과 재량과의 구별논의에 대해서 서술하시오.(10점)

물음 3) 판단여지와 재량을 구별하지 않는 판례의 태도에 따를 때, 법원이 국토교통부장관의 감정평가사 선발인원 결정에 대해 심리할 수 있는 범위와 한계를 검토하시오.(5점)

<참고조문>

[감정평가법 시행령] 제10조(합격기준)

② 국토교통부장관은 감정평가사의 수급 상황 등을 고려하여 제2차 시험의 최소합격인원을 정할 수 있다. 이 경우 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐야 한다.

【문제 3】 국토교통부장관은 감정평가법인등 甲이 수수료의 요율 및 실비 기준을 준수하지 않은 사실을 적발해서 2년간의 업무정지 처분을 내렸다. 다만, 甲이 [부동산공시법] 제3조에 따른 표준지공시지가 공시 등 업무를 정상적으로 수행하는 데 지장이 생길 우려가 있어, 업무정지 처분을 대신해 5천만원의 과징금을 부과하였다.(15점)

물음 1) 하명의 개념과 종류를 설명하고, 과징금 부과처분이 어떤 하명에 해당하는지 검토하시오.(5점)

물음 2) 재량행위와 기속행위의 구별 실익과 기준에 대하여 설명하고, 과징금 부과처분이 재량행위인지 검토하시오. (10점)

<참고조문>

[감정평가법] 제41조(과징금의 부과)

① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

【문제 4】 강학상 허가에 대하여 서술하고, 예외적 승인과 차이점을 설명하시오.(15점)

【문제 5】 A등은 감정평가법인을 설립하여 국토교통부장관의 설립인가를 받았다. 설립인가 자체의 하자는 없지만, 감정평가법인의 사원에 관한 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」의 요건을 충족하지 못하여 설립행위에 문제가 있음을 확인한 경쟁업체의 감정평가사 甲은 소송을 통하여 이를 다투고자 한다. 이러한 ①감정평가법인의 설립행위(기본행위)와 인가행위의 관계를 설명하고, ②쟁송방법에 대하여 검토하시오. (판례에 의하면, 감정평가법인의 설립행위와 관련된 분쟁은 민사소송으로 다루는 것을 전제로 한다.)(10점) [36회 문4 변형]

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 택지조성사업을 하고자 하는 기업자 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 甲의 사업인정신청에 대해 국토교통부장관은 택지조성사업 면적의 50%를 택지 이외의 다른 목적을 가진 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 甲은 해당 부관의 내용이 너무 과다하여 수익성을 도저히 맞출 수 없다고 판단하여 취소소송을 제기하려 한다. (40점) [13회 문1 기출 변형]

물음1) 부관의 개념과 종류를 설명하고, 甲의 사업인정에 부가된 기부채납의 조건이 어떤 부관에 해당하는지 논하시오. (10점)

물음2) 부관의 한계를 설명하시오. (10점)

물음3) 부관의 독립쟁송가능성에 대하여 논하시오. (10점)

물음4) 부관만의 독립취소가능성에 대하여 논하시오. (10점)

참조 조문
[공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률] 제2조(정의) 7. “사업인정”이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.
제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다

[행정기본법]

제17조(부관)

① 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.

④ 부관은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것
2. 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것
3. 해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것

【문제 2】 뉴타운(New Town)개발이 한창인 A지역 인근에 주택을 소유한 P는 자신의 주택에 대하여 전년도 대비 현저히 상승한 개별공시지가를 확인하고 향후 부과될 관련 세금의 상승 등을 우려하여 부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 이의신청을 하였으나 기각되었다. P는 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 90일 이내에 쟁송제기를 하지 않아서 불가쟁력이 발생하였다. 그 후 P는 자신이 소유한 주택에 대하여 전년도보다 높은 재산세(부동산보유세)를 부과 받게 되었다.

P가 소유 주택에 대하여 확정된 개별공시지가가 위법함을 이유로, 그 개별공시지가를 기초로 부과된 재산세에 대한 취소청구소송을 제기할 수 있는지에 대하여 논술하시오. (개별공시지가에는 취소사유의 위법성이 있다고 전제한다.)(20점) [21회 문2번 변형]

참조 조문

[부동산 가격공시에 관한 법률]

제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구부동산 가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

[행정기본법]

제36조(처분에 대한 이의신청)

④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제1항의 처분(이의신청 결과 처분이 변경된 경우에는 변경된 처분으로 한다)에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다

【문제 3】 행정행위의 직권취소에 대한 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 처분청이 행하는 행정행위의 직권취소에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 직권취소의 취소시 원행정행위의 효력이 회복되는지에 대하여 논하시오.(10점)

【문제 4】 행정행위의 철회에 대하여 설명하시오.(15점)

【문제 5】 하자치유의 개념과 인정필요성을 설명하고, 하자치유의 시간적 한계에 대해서 논하시오.(15점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토교통부장관은 A시의 무분별한 확산을 방지하고 주변 자연환경을 보전하여 시민들의 쾌적한 생활환경을 보장하고자, 「국토계획법」 제38조에 따라서 甲의 토지를 포함한 일부 지역을 개발제한구역으로 지정하였다. 그 결과 甲은 새로운 건축물의 건축이 불가능해지고, 토지의 형질 변경 역시 제한을 받게 되었다.(35점)

물음 1) 개발제한구역 지정(행정계획)의 법적 성질에 대하여 논하시오.(10점)

물음 2) 계획재량과 행정재량의 구분 여부에 대하여 논하시오. (10점)

물음 3) 계획재량의 통제에 대하여 설명하시오. (5점)

물음 4) 甲은 국토교통부장관에게 개발제한구역의 지정해제를 청구하고자 한다. 甲의 청구가 받아들여질 수 있는지에 대하여 논하시오. (10점)

<참고조문>

[국토계획법] 제38조(개발제한구역의 지정)

① 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

[국토계획법] 제80조(개발제한구역에서의 행위 제한 등)

개발제한구역에서의 행위 제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

[개발제한구역법] 제12조(개발제한구역에서의 행위제한)

① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다

【문제 2】 감정평가사 甲은 [감정평가법 시행령] 제18조에 따라 5년의 갱신 기간이 도래하여 국토교통부장관 乙에게 갱신등록을 신청했으나, 거부처분을 받았다. (30점)

물음 1) 국토교통부장관이 거부처분을 하면서 행정절차법상 사전통지 하지 않은 경우, 해당 거부처분이 위법한지 논하시오.(15점)

물음 2) 국토교통부장관이 거부처분을 하면서 이유제시를 하지 않은 경우, 절차상 하자의 독자적 위법성이 인정되는지 여부를 논하시오. (15점)

<참고조문>

[감정평가법 시행령] 제18조 (갱신등록)

① 법 제17조제1항에 따라 등록한 감정평가사는 같은 조 제2항에 따라 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.

【문제 3】 행정상 사실행위의 종류를 설명하고, 위법한 사실행위가 발생했을 때 가능한 권리구제 방법에 대해 논하시오.(15점)

【문제 4】 [행정절차법]상 청문에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 확약의 법적성질에 대하여 논하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 A시장은 위법 건축물의 소유자 甲에게 위법건축물을 일정기간까지 철거할 것을 명함과 아울러 불이행할 때에는 대집행한다는 내용의 철거대집행 계고처분을 고지하였다. 그 후 甲이 이에 불응하자 다시 제2차, 제3차 계고서를 발송하여 일정기간까지의 자진철거를 촉구하고 불이행하면 대집행을 한다는 뜻을 고지하였다. (40점)

물음 1) 행정법상 대집행의 의의 및 요건에 대하여 설명하시오. (10점)

물음 2) 대집행의 절차에 대하여 설명하시오. (10점)

물음 3) 계고의 법적성질에 대하여 설명하고 甲이 계고에 대하여 불복시 소송의 대상이 되는 계고가 무엇인지 논하시오. (10점)

물음 4) 취소소송이 기각되어 행정대집행이 실행되는 과정에서 甲이 의무 이행을 거부하면서 저항하는 경우, 행정청은 이러한 저항을 실력으로 배제할 수 있는지에 대해 논하시오. (10점)

【문제 2】 감정평가사 甲은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가준칙을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2021. 4. 1. 甲에게 업무정지처분을 갈음하여 각 3천만원의 과징금을 부과하였다. 다음 물음에 답하시오.(20점) (30점)

물음 1) 과징금의 종류 및 법적성질에 대하여 설명하시오. (10점)

물음 2) 甲이 과징금을 납부하지 않을 경우 적용되는 제재수단과, 과징금 처분에 대해 불복할 수 있는 방법을 설명하시오. (10점)

물음 3) 국토교통부장관은 과징금과 벌금을 중복하여 부과하고자 한다. 중복부과 처분의 가능성에 관하여 논하시오. (10점)

<참고조문>

[헌법] 제13조

① 모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다.

[감정평가법] 제41조 (과징금의 부과)

① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제44조(과징금의 징수와 체납처분)

① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.

② 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다

【문제 3】 공익사업의 준비절차로 토지보상법 제9조에 사업시행자가 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량·조사를 할 수 있는 규정을 두고 있다. (20점)

물음 1) 토지보상법 제9조의 타인점유 토지에 출입하여 측량·조사 행위의 법적 성질을 설명하고 토지점유자가 조사를 거부하거나 방해할 경우 실력으로 강제조사를 할 수 있는지 논하시오. (10점)

물음 2) 타인토지 출입하여 측량·조사행위시 통지의무를 결여한 경우 이에 근거한 사업인정도 위법한지 논하시오. (10점)

<참고조문>

[토지보상법] 제9조(사업 준비를 위한 출입의 허가 등)

① 사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.

제10조(출입의 통지)

① 제9조제2항에 따라 타인이 점유하는 토지에 출입하려는 자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게 통지하여야 한다.

제11조(토지점유자의 인용의무)

토지점유자는 정당한 사유 없이 사업시행자가 제10조에 따라 통지하고 출입·측량 또는 조사하는 행위를 방해하지 못한다.

【문제 4】 명단의 공표의 법적 성질에 대하여 논하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 감정평가사무소를 운영하는 감정평가사 甲은 감정평가사 乙을 소속 감정평가사로 고용하였다. 국토교통부장관은 乙이 결격사유에 해당한다는 이유로 해당 고용신고의 수리를 거부하였다. 이로 인해 甲은 소속 감정평가사가 아닌 자를 통하여 감정평가 업무를 수행한 것으로 간주되어 벌금이 부과될 가능성이 있다. (25점)

물음 1) 신고의 종류 및 구별 실익에 대하여 설명하시오. (5점)

물음 2) 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고의 구별기준에 대하여 논하시오. (10점)

물음 3) 감정평가사 乙의 고용신고 거부에 대하여 甲이 소송을 제기할 수 있는지, 그 대상적격을 검토하시오. (감정평가사의 고용신고는 자기완결적 신고로 본다) (10점)

<참고조문>

[감정평가법] 제17조(등록 및 갱신등록)

① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 제10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

제21조(사무소 개설 등) ⑤ 감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다. 이 경우 소속 감정평가사는 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 아니어야 하며, 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

제21조의2(고용인의 신고) 감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로

정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

제50조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다

2. 제21조제5항 또는 제29조제9항을 위반하여 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조의 업무를 하게 한 자

【문제 2】 감정평가사 甲은 친족 소유 토지를 평가한 것이 적발되어 국토교통부장관으로부터 3개월 업무정지 처분을 받았으나, 국토교통부장관은 부동산 가격 공시 업무에 지장을 줄 우려가 있다며 업무정지에 갈음하여 3천만 원의 과징금을 부과하였다. 甲은 부과된 과징금이 지나치게 과중하다는 이유로 국토교통부장관에게 이의신청을 하였고, 이에 대해서 국토교통부장관은 甲에 대하여 과징금을 2천만원으로 감액하는 결정을 하였다. 甲은 감액된 2천만원의 과징금도 과중하다고 생각하여 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하고자 한다. (25점)

물음 1) 이의신청과 행정심판의 구별실익 및 구별기준에 대해서 논하시오.(15점)

물음 2) 甲이 행정소송을 제기할 때, 소송의 대상이 무엇인지 논하시오. (10점)

<참고조문>

[행정심판법] 제51조(행정심판 재청구의 금지)

심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없다.

[감정평가법] 제42조(이의신청) ① 제41조에 따른 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 30일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.

③ 제2항에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 청구할 수 있다.

【문제 3】 행정소송의 소의 대상과 관련하여 원처분주의와 재결주의의 개념에 대해서 서술하고, 인용재결에 고유한 위법이 있는 경우에 대해서 서술하시오.(15점)

【문제 4】 행정청의 거부행위가 처분이 되기 위한 요건을 설명하시오. (15점)

【문제 5】 대상적격과 관련하여 행정청이 직권으로 처분을 변경하는 경우(변경 처분) 소의 대상에 대해서 설명하시오. (10점)

【문제 6】 행정심판법상 가구제수단인 임시처분에 대하여 설명하시오. (10점)

<참고조문>

[행정심판법]제31조(임시처분)

① 위원회는 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우로서 처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위하여 임시지위를 정하여야 할 필요가 있는 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.

② 제1항에 따른 임시처분에 관하여는 제30조제3항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 같은 조 제6항 전단 중 “중대한 손해가 생길 우려”는 “중대한 불이익이나 급박한 위험이 생길 우려”로 본다.

③ 제1항에 따른 임시처분은 제30조제2항에 따른 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 감정평가사 甲은 감정평가를 함에 있어 감정평가준칙을 준수하지 아니하였음을 이유로 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]에 따라서 2개월의 업무정지처분을 받았다. (각 물음은 상호독립적임) (40점)

물음 1) 甲은 처분의 효력발생일로부터 2개월이 경과한 후 제소기간 내에 국토교통부장관을 상대로 업무정지처분 취소소송을 제기하였다. 甲은 취소소송을 제기할 소의 이익이 있는지 논하시오. (20점)

물음 2) 甲이 업무정지 처분을 받은 직후 취소소송을 제기하고 집행정지를 신청한 경우, 집행정지 인용 가능성에 대해 논하시오. (甲은 업무 정지 시 고객 이탈로 인해 회복되기 어려운 손해가 발생할 것으로 본다) (20점)

<참고조문>

[감정평가법 시행령] 제29조 [별표3]

위반행위	근거	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
감정평가서의 발급을 정당한 이유 없이 지연한 경우	법 제32조 제1항 제6호	업무정지 15일	업무정지 1개월	업무정지 2개월
감정평가서의 기재사항에 중대한 하자가 있는 경우		업무정지 1개월	업무정지 2개월	업무정지 4개월

【문제 2】 감정평가사 甲은 2025.10.10.에 친족 소유 토지를 평가한 사실이 적발되어 국토교통부장관으로부터 3개월 업무정지 처분을 받았다. 이에 甲은 처분이 과중하다며 업무정지 처분 취소 소송을 제기하였다. 소송 진행 중 국토교통부장관은 甲이 2025년 8월 1일 다른 건의 토지를 평가하는 과정에서 수수료 및 실비 외에 현금을 수수한 사실을 적발하여, 이를 처분 사유에 추가하고자 한다. 처분 사유의 추가 또는 변경이 가능한지에 대해 논하시오. (25점)

【문제 3】 행정소송법 제12조는 처분 등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자만이 취소소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다. ① 여기서 말하는 법률상 이익의 의미를 논하고, ② 제3자의 원고적격 중 인인소송에 대하여 설명하시오. (20점)

【문제 4】 행정소송법상 제소기간에 대하여 설명하시오. (15점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국가배상과 관련하여 다음 물음에 답하시오.(50점)

물음1) 국가배상청구권과 국가배상책임의 법적성질에 대하여 논하시오.(10점)

물음2) 국가배상청구권이 성립하는 경우 가해 공무원 개인도 피해자에 대하여 배상책임을 지는지 논하시오.(10점)

물음3) 국가배상책임의 성립요건에 대하여 논하시오.(20점)

물음4) 취소소송의 확정판결이 난 후, 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 논하시오.(10점)

[관련조문]

[헌법] 제29조

① 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다.

[국가배상법] 제2조(배상책임)

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 “공무원”이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다.(이하 생략)

② 제1항 본문의 경우에 공무원에게 고의 또는 중대한 과실이 있으면 국가나 지방자치단체는 그 공무원에게 구상(求償)할 수 있다.

【문제 2】 각 물음에 대하여 설명하시오. (30점)

물음 1) 행정소송법 제30조의 기속력에 대하여 설명하시오. (20점)

물음 2) 행정소송법 제34조의 간접강제의 의의 및 요건등을 설명하시오. (10점)

【문제 3】 행정소송법 제28조의 사정판결에 대하여 설명하시오. (20점)

0기 1주차 예시답안

문 1) 35점	
I. 물음 #1	
1. 쟁점의 정리	표준지공시지가 조사 평가 기준과 같이 상위법령의 위임을 받아 법령을 보충하는 법령보충적 행정규칙의 법적 성질(대외적 구속력)에 대하여 검토한다.
2. 법령보충적 행정규칙의 의의 및 법적 성질	
1) 법령보충적 행정규칙의 의의 및 근거	① 법률의 위임에 의해 법령을 보충하는 법규사함을 정하는 행정규칙을 말한다. ② <행정기본법 제2조 제1호 가목의 법령>으로 이를 명문화 하고 있다.
2) 법적성질 (대외적 구속력 인정논의)	
(1) 학설	
① 법규명령설(실질설)	법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.

② 행정규칙설(형식설)	법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다
③ 수권여부기준설	상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.
④ 규범구체화 행정규칙	대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다
(2) 판례	
① <대법원>은 행정규칙의 형식으로 제정된 것이라도 상위법령의 위임이 있고, 위임의 한계를 벗어나지 않으며, 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 가지는 경우에는 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령이라고 보았다.	
② <헌법재판소>는 헌법이 인정하고 있는 위임입법	

의 형식은 예시적인 것이라 하면서 대법원의 입장과 마찬가지로 법령보충적 행정규칙의 대외적 구속력을 인정한다	
(3) 검토	
① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 대외적 구속력을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다. ② 다만, 일반적인 법규명령절차를 거치지 않기 때문에 국민의 예측가능성을 고려하여 고도의 전문적 영역에 한정되어 최소한도로 인정해야 할 것이다.	
3. 사안의 해결	표준지공시지가 조사, 평가 기준은 상위법령인 부동산공시법 제3조 4항 및 동법 시행령 제6조 제3항에 따라 위임이 있으므로 그와 결합하여 <대외적 구속력 있다고> 본다.
III. 물음 #3	
1. 개설	법령보충적 행정규칙의 사법적 통제 수단으로 ① 직접적 통제 가부와 ② 구체적 규범통제 및 ③ 헌법재판

소에 의한 통제에 대하여 검토한다.	
2. 직접적 통제 가부 (가점)	
① 행정입법은 일반적, 추상적 규범이므로 원칙상 처분이 아니므로 항고소송의 대상이 될 수 없다. ② 다만, 명령(법령보충적 행정규칙 포함) 중 처분적 성질을 갖는 명령(처분적 명령)은 항고소송의 대상이 된다는 것이 일반적 견해이다.	
③ <사안에서> 표준지공시지가 조사, 평가기준은 일반적, 추상적 규범으로 항고소송의 대상인 <처분>으로 볼 수 없다고 본다. 따라서, <직접적 통제수단은 불가>할 것이다.	
3. 구체적 규범통제	
1) 의의 (헌법 제107조 제2항)	사인이 구체적인 처분을 소송으로 다투면서 위법성의 근거로, 처분의 근거가 된 법규명령(법령보충적 행정규칙 포함)의 위헌, 위법을 주장하는 것을 말한다.
2) 통제의 대상	구체적 규범통제의 대상은 명령과 규칙이 된다. ①

명령은 법규명령을 의미하고, ②규칙은 대법원규칙, 국회규칙, 지방자치단체의 조례와 행정규칙 중 법규성을 갖는 <법령보충적 행정규칙>등을 의미한다.
3) 통제의 주체
<각급 법원>이 통제하고 최종적인 심사권은 헌법 제107조 제2항에 따라서 <대법원>에 있다.
4) 효력
(1) 학설
① 개별적 효력설
구체적 규범통제는 재판의 전제가 된 경우에만 가능하고, 법원은 구체적 사건의 심사를 목적으로 하며 법령의 심사를 목적으로 하지 않으므로 해당 사건에 한하여 적용되지 않는다고 본다.
② 일반적 효력설
대법원의 판결이 있는 경우에 당해 명령은 일반적으로 효력을 상실한다고 본다.
(2) 판례
① <판례>는 구체적 규범통제를 통해 위법한 것으로

판결된 법령에 대해서는, 문제가 된 당해 사건에 한하여 적용되지 않는다고 판시한 바 있다.
(3) 검토
행정소송법 제6조는 대법원에서 위헌·위법으로 판단된 명령·규칙이 다른 사건에 적용됨을 방지하기 위하여 이를 관보에 공고하는 것이므로 <개별적 효력설>이 타당하다고 본다.
4. 헌법재판소에 의한 통제
1) 문제점
법규명령(명령·규칙)이 재판의 전제성이 없는 경우에 헌법소원의 대상적격이 있는지에 대하여 대법원과 헌법재판소의 견해가 나뉜다.
2) 대법원 및 헌법재판소의 태도
① <대법원>은 헌법 제107조 제2항에서 명령·규칙에 대한 심사권은 법원에 부여하고 있으므로, 헌법재판소는 법규명령에 대한 위헌심판권을 갖지 않는다고 한다.
② <헌법재판소>는 <법무사법 시행규칙>에 대한 결정례에서 재판의 전제가 되는 경우가 아닌 명령·규칙

이 그 자체에 의하여 직접 국민의 기본권을 침해하는 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 본다.
3) 검토
① 헌법소원제도의 기본권보장제도로서의 기능을 보장하기 위하여 명령·규칙에 대한 헌법소원을 인정하는 것이 타당하다. ② 다만, 헌법 제107조 제2항을 고려하여 권리구제형 헌법소원을 제기하기 위해서는 법규명령으로 인해 국민의 <기본권이 현재 직접적으로 침해>되고, 다른 법률이 정한 구제절차를 모두 거친 뒤에도 구제되지 않은 경우에만(보충성) 헌법소원을 청구할 수 있다고 본다.
- 끝 -

문2) : 25점
I. 물음#1
1. 쟁점의 정리
국토교통부장관은 택지면적의 60%를 당해 사업과 실질적 관련성 없는 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 기부채납 조건이 부당결부 금지의 원칙에 반하는지 검토한다.
2. 사업인정의 의의 및 법적성질(토지보상법 제20조)
① 사업인정이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.(토지보상법 제2조 제7호) ② 판례는 사업시행자가 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 공공수용권을 설정하는 <행정처분>이며, 외관상 공익사업임에도 공익성 여부 등 모든 사항을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 <재량행위>라고 판시한 바 있다.
3. 부당결부 금지의 원칙에 반하는지 여부
1) 부당결부 금지의 원칙의 의의 및 근거
① 행정기관이 행정권을 행사함에 있어서 그것과 실질적인 관련이 없는 반대급부를 결부시켜서는 안된

다는 원칙을 말한다. ② 이는 행정기본법 제13조에 근거를 둔다.
2) 요건
① 행정청의 공권력 행사가 있고, ② 공권력 행사가 상대방의 반대급부와 결부되고, ③ 공권력 행사와 반대급부간 실질적 관련성이 없을 것을 요건으로 한다.
3) 실질적 관련성 여부
실질적 관련성은 ① 행정작용과 반대급부간 인과관계가 있는지 여부인 <원인적 관련성>과 ② 행정작용과 반대급부가 동일한 목적인지 <목적적 관련성> 여부로 판단한다.
4) 사안의 경우
① 행정청의 공권력 행사인 사업인정이 있고, ② 사업인정시 반대급부인 기부채납 조건이 결부되며, ③ 사업인정과 기부채납간 <실질적 관련성이 없는바> 부당결부 금지의 원칙에 반한다.
4. 사안의 해결
택지면적의 60%를 해당 사업과 실질적인 관련 없는

공공용지로 조성하는 기부채납조건은 사업인정과 실질적 관련성이 없는바 <부당결부금지의 원칙>에 반한다고 본다.
II. 물음 #2
1. 쟁점의 정리
택지조성사업시 택지면적의 60%를 기부채납 조건이 비례의 원칙에 반하는지를 검토한다.
2. 비례의 원칙
1) 의의 및 근거
① 행정작용에 있어 행정목적과 행정수단 사이에는 합리적인 비례의 관계가 있어야 한다는 원칙을 말한다. ② 헌법적 근거로 헌법 제37조 제2항으로 도출되며, 행정기본법 제10조에 근거를 둔다.
2) 내용
(1) 적합성의 원칙
적합성의 원칙이란 행정목적 달성을 위하여 적합한(유용한) 수단을 선정하여야 한다는 원칙을 말한다.

(2) 필요성의 원칙
행정목적 달성에 적절한 수단이 여러 가지인 경우에는 국민의 권리를 최소한으로 침해하는 수단을 선택하여야 한다는 원칙이다.
(3) 상당성의 원칙
상당성의 원칙이란 달성되는 공익보다 침해되는 사익이 더 커서는 안된다는 원칙을 말한다. 이를 협의의 비례의 원칙이라고도 한다.
(4) 3원칙의 상호관계
적합성의 원칙, 필요성의 원칙, 상당성의 원칙은 서로 단계적 심사과정을 거쳐서 비례의 원칙 위반 여부를 판단한다.
(5) 사안의 경우
① 사업인정시 기부채납을 부과하는 것은 공공용지 확보를 위하여 적합한 수단이고, ② 택지 조성 면적의 일부를 기부채납하는 것은 최소침해하는 수단에 해당하나, ③ 택지면적의 60%를 기부채납하도록 하여 사업성에 문제가 발생하는 것은 달성되는 공익보다 침해되는 사익이 현저히 크다고 판단되므로 <상당성

의 원칙>에 반한다고 본다.
3. 사안의 해결
사업인정시 택지면적의 60%를 기부채납하도록 하는 것은 달성되는 공익에 비해서 침해되는 사익이 크다고 판단되므로 비례의 원칙에 반한다고 본다.
- 끝 -

문3) : 20점	
I. 개설	헌법 제11조에서는 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 규정한다. 법의 일반원칙 중 ①평등의 원칙과 ②자기 구속의 원칙에 대하여 각각 검토한다.
II. 평등의 원칙	
1. 의의 및 근거	①불합리한 차별을 하여서는 안된다는 원칙이다. 따라서 합리적인 이유가 있어서 다르게 취급하는 것은 평등의 원칙 위반이 아니다. ②헌법 제11조로부터 도출되는 불문법 원칙으로서 행정기본법 제9조에 이를 명문화하고 있다.
2. 요건 및 한계	①합리적 이유 없이 동일한 사항을 다르게 취급하는 것은 평등의 원칙에 반한다. ②단, 불법 앞의 평등요구는 인정되지 않는다.
III. 자기구속의 원칙	
1. 의의 및 근거	

①행정관행이 성립된 경우 행정청은 특별한 사정이 없는 한 같은 사안에서 행정관행과 같은 결정을 하여야 한다는 원칙을 말한다. ②이는 평등의 원칙에 근거하며 자기구속의 원칙에 반하는 행정권 행사는 위법한 것이 된다.	
2. 요건(내용)	①재량행위이고, ②행정관행과 동일한 사안이며, ③행정선례가 있을 것을 요한다.
3. 선례필요 여부에 대한 견해의 대립	
1) 학설	①반복적인 행정선례가 필요하다는 <선례필요설>과 ②1회 행정선례로 족하다는 <1회 선례충분설>, ③재량준칙의 존재만으로 자기구속을 인정할 수 있다는 <선례불요설> 등이 대립한다.
2) 판례	판례는 재량준칙이 공표된 것만으로 자기구속원칙이 적용될 수 없고, 되풀이 시행되어 행정관행이 성립되어야 한다고 선례필요설의 입장이다.

3) 검토	
①<1회 선례충분설>은 행정을 경직화시킬 우려가 있고, ②<선례불요설>은 행정규칙(재량준칙)의 법규성을 인정하는 결과를 초래할 수 있는 바 <선례 필요설>이 타당하다고 본다.	
4. 한계	①위법한 관행의 경우와 ②사정변경으로 행정관행과 다른 처분을 할 공익상 필요가 큰 경우에는 자기구속의 원칙 적용이 배제될 수 있다.
5. 재량준칙과의 관계 (가점)	①재량준칙(행정규칙)은 대외적 구속력이 없어 행정규칙을 위반하였다고 하여 위법한 행정행위가 되는 것은 아니다. ②그러나, 행정청이 재량준칙을 마련하여 이에 따라 반복하여 행정작용을 하였을 경우, 자기구속의 원칙에 의해 재량준칙은 간접적으로 대외적 구속력을 갖게 된다.
- 끝 -	

문4) : 10점	
I. 쟁점의 정리	법규명령형식의 행정규칙은 형식은 법규명령이나 실질적으로 행정 내부의 사무처리기준인 행정규칙이다. 따라서 법규명령 형식의 행정규칙의 <대외적 구속력 여부>에 대하여 검토한다.
II. 법규명령형식의 행정규칙의 법적 성질	
1. 법규명령형식의 행정규칙의 의의	법규명령의 형식을 취하고 있지만 그 내용이 행정규칙의 실질을 가지는 것을 말한다.
2. 법적 성질	
1) 학설	
(1) 법규명령설	규범의 형식을 중시하고 법적 안정성 확보를 위해 법규명령으로 보는 견해를 말한다.
(2) 행정규칙설	규범의 실질을 중시하고 구체적 타당성을 중시하여 행정규칙으로 보는 견해이다.

(3) 수권여부기준설
상위법령의 수권여부를 기준으로 판단하는 견해로서, 상위법령의 수권에 근거하여 제정되었다면 법규명령으로 보고 위임이 없이 제정되었다면 행정규칙으로 본다.
2) 판례
(1) 제재적 처분기준인 경우
① 판례는 <부령형식>으로 정해진 제재적 처분기준은 그 성질과 내용이 <행정규칙>의 성질을 가지는 것에 불과하다고 보았다.
② 다만, <대통령령의 형식>으로 규정된 경우 <법규명령>으로 보았으며, 일부 판례에서는 재량권 행사의 여지를 인정하기 위하여 처분기준을 정액이 아닌 처분의 최고한도액이라고 보았다.
(2) 수익적 처분기준인 경우
판례는 [여객자동차운수사업법 시행규칙] 조문들에 대해 법규명령이라고 판시함으로써, 수익적 처분기준인 경우 시행규칙에 규정되어 있어도 법규명령으로 본 예가 있다.

3) 검토 (판례에 대한 비판)
제재적 처분기준의 대통령령과 부령 모두 헌법 제75조 및 제95조에 근거한 형식이며 법규명령으로서 절차적 정당성이 부여되어 있으므로 국민의 예측가능성을 보장하는 측면에서 형식을 기준하여 법규명령으로 보는 <법규명령설>이 타당하다.
- 끝 -

문5) : 10점
I. 개설(의의 및 근거)
① 신뢰보호 원칙이란 행정기관의 적극적 또는 소극적 언동에 대한 국민의 보호가치 있는 신뢰는 보호하여 주어야 한다는 원칙을 말한다. ② 이는 행정기본법 제12조 및 행정절차법 제4조 제2항에 근거를 둔다.
II. 요건
1. 행정기관의 선행조치
행정기관의 상대방인 국민에 대한 신뢰를 주는 어떠한 선행조치가 있어야 한다. 선행조치는 적극적인 행위뿐만 아니라 소극적인 행위와 묵시적인(소극적인) 행위도 포함된다.
2. 보호가치 있는 신뢰
선행조치에 대한 상대방의 신뢰가 보호가치 있는 것이어야 한다. 즉, 상대방 등에게 귀책사유(책임있는 사유)가 있어서는 안된다.
3. 상대방의 조치

상대방인 국민이 행정기관의 선행조치에 대한 신뢰에 입각하여 어떠한 조치를 취하여야 한다. 단순히 선행조치를 신뢰한 것만으로는 부족하고, 사인의 후행 조치가 필요하다.
4. 인과관계
인과관계란 전자가 존재하여 후자가 발생하는 관계를 말한다. 행정기관의 선행조치와 이를 신뢰하고 행한 국민의 조치 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다.
5. 선행조치에 반하는 후행행위
행정기관이 선행조치를 하였고 이를 신뢰한 상대방이 일정한 조치를 하였는데, 행정기관이 상대방의 신뢰에 반하는 행정권의 행사를 하여 상대방의 권익이 침해되어야 한다.
III. 한계
① 법률 적합성의 원칙(공익 추구)과 신뢰보호의 원칙(사익추구)이 서로 충돌시에는 이익 상호간 이익형량을 하여야 한다. ② 또한 공적견해표명(선행조치)이 있는 후 사정변경되어 견해표명의 효력을 잃게

된 경우에는 국민은 신뢰보호원칙을 주장할 수 없다.

IV. 위반시 효과

신뢰보호원칙에 위반한 행정작용은 위헌, 위법한 행정작용이 되며 행정쟁송 및 국가배상을 청구할 수 있다.

- 끝 -

- 이하여백 -

0기 2주차 예시답안

문 1) : 40점 <0기 2주차 예시답안>	
I. 물음#1	
1. 쟁점의 정리	공정력의 개념에 대해서 알아보고, 구성요건적효력이 공정력과 구별되는 독자적인 개념인지에 대해서 알 아본다.
2. 공정력	
1) 의의	행정행위가 당연무효가 아닌 한 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지 상대방 및 이해관계인에 대해 여 일단 유효한 것으로 통용되는 힘을 말한다.
2) 근거	①<이론적 근거>로는 행정목적의 신속한 달성, 행정 법관계의 안정성 유지, 상대방의 신뢰보호 등과 같은 정책적 고려에서 구하는 법적 안정성설이 통설이고, ②<실정법상 근거>로 행정기본법 제15조에 근거를 둔다.
3. 공정력과 구성요건적 효력의 구별논의	
1) 구성요건적 효력의 의의 및 근거	①유효한 행정행위가 존재하는 이상 처분청 이외의

다른 국가기관은 그의 존재를 스스로의 판단 기초	
내지는 구성요건으로 삼아야 한다는 구속력을 말한	
다. ②실정법상 근거는 없으나, <국가기관 상호간의	
권한 존중의 원칙>을 이론적 근거로 본다.	
2) 공정력과 구성요건적 효력의 구별	
(1) 학설 및 판례	①공정력을 넓게 이해하여 구성요건적 효력을 공정 력의 한 내용으로 보는 <비구별설>과 ②공정력은 행 정행위의 상대방 또는 이해관계인에 대한 구속력이 고, 구성요건적효력은 처분청 이외의 다른 국가기관 에 대한 구속력으로서 양자는 차이가 있다고 보는 <구별설>이 대립한다. ③<판례>는 양자를 비구별하 는 입장이다.
(2) 검토	①공정력은 <상대방 또는 이해관계인>에 대한 구속 력인 반면, ②구성요건적 효력은 <처분청 이외의 다 른 국가기관>에 대해 구속력을 가지므로, 구별설이 타당하다. 따라서 선결문제는 <구성요건적 효력을 기준>으로 검토한다.

II. 물음#2	
1. 쟁점의 정리	행정소송법 제11조 제1항에서 당연무효인 경우 처분 등의 효력 유무 및 존재 여부를 심사할 수 있다고 규정하고 있으나, 단순위법(취소사유)인 경우 민사법 원이 행정행위의 위법성을 심사할 수 있는지가 문제 된다.
2. 민사법원에서 행정행위의 위법여부가 쟁점인 경우	
1) 학설	
(1) 긍정설	①구성요건적 효력은 행정행위의 적법성 추정이 아 니라, 유효성이 잠정적으로 통용되는 효력에 불과하 고 ②행정소송법 제11조 제1항은 선결문제심사권에 대한 <예시적 규정>에 불과하므로, ③민사법원이 행 정행위의 위법성 여부를 심사하는 것은 구성요건적 효력에 반하지 않는다는 견해이다.
(2) 부정설	①구성요건적 효력은 행정행위의 적법성 추정을 의 미한다는 점, ②행정행위의 위법성 판단은 항고소송 을 제기받은 행정법원만이 배타적 관할을 가진다는

점, ③행정소송법 제11조 제1항은 <처분의 효력 유	
무 또는 존재 여부>에 대해서는 심리할 수 있다고	
규정하고 있으나, <위법여부>는 규정이 없는 바, 민	
사법원이 위법성 판단에 대한 심사권을 가질 수 없	
다는 입장이다.	
2) 판례	계고처분이 위법임을 이유로 손해배상을 청구한 사 안에서 행정처분의 취소판결이 있어야만 손해배상을 청구할 수 있는 것은 아니라고 보아 <긍정설>의 입 장을 취하고 있다.
3) 검토	구성요건적 효력은 행정행위의 적법성을 추정하는 효력은 아니고 행정행위의 위법여부를 묻지 않고 취 소되기 전까지 잠정적으로 유효한 것으로 처분청 이 외의 다른 국가기관을 구속하는 효력이므로 <긍정 설>이 타당하다.
III. 물음#3	
1. 쟁점의 정리	행정행위의 효력유무가 민사소송의 선결문제가 되는

경우, 행정행위가 당연무효가 아닌 단순위법(취소사유)에 불과한 경우, 민사법원이 행정행위의 효력을 부인할 수 있는지가 문제된다.
2. 행정행위의 무효확인이 선결문제인 경우
① <무효인 행정행위>는 구성요건적 효력이 없기 때문에 민사법원은 행정행위의 무효를 확인할 수 있다.
② 또한 행정소송법 제11조 제1항에서도 <처분등의 효력 유무>가 민사소송의 선결문제인 경우 민사법원이 이를 심리*판단할 수 있다고 규정하고 있다.
3. 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제인 경우
① 행정행위가 단순위법인 경우에는 민사법원은 행정행위의 구성요건적 효력으로 인해 행정행위의 효력을 부인할 수 없다고 본다. ② 판례도 그 하자가 단순 취소사유의 그칠 경우 민사법원은 그 효력을 부인할 수 없다고 판시한 바 있다. ③ <생각건대> 행정행위의 구성요건적 효력과 현행법상 취소소송의 배타적 관할권을 고려할 때 <부정설>이 타당하다고 본다.
IV. 물음#4
1. 쟁점의 정리

행정행위의 위법여부가 형사소송의 범죄구성요건 판단의 선결문제가 된 경우, 형사법원이 행정행위의 위법여부를 심사할 수 있는지에 대해 별도의 규정이 없어서 문제가 된다.
2. 형사법원에서 행정행위의 위법 여부가 쟁점인 경우
1) 학설
① 구성요건적 효력은 적법성 추정이 아니라 단순히 유효성이 잠정적으로 통용되는 효력에 불과하다는 점, 행정소송법 제11조 제1항은 선결문제 심사권에 대한 예시적 규정으로 보는 <긍정설>과 ② 행정행위에는 구성요건적 효력이 있고, 행정소송법 제11조에서 형사소송에 대한 규정이 없어 불가하다고 보는 <부정설>이 있다.
2) 판례
행정청으로부터 시정명령을 받은 자가 이를 위반한 경우, 관련 법률에 따라 처벌하기 위해서는 그 시정명령이 적법해야 하며, 시정명령이 당연무효가 아니더라도 위법하다고 인정되는 한 개별제한구역법 상의 위반죄는 성립할 수 없다는 점에서 <긍정설>을 취하고 있다.

3) 검토
① 행정소송법 제11조 제1항을 반드시 제한적 열거규정으로 해석하여야 하는 것은 아니라는 점, ② 구성요건적 효력은 행정행위의 효력과 관련된 것이므로 행정행위의 위법성 판단이 곧 효력을 부인하는 것은 아니라는 점등을 비추어 볼 때, <긍정설>이 타당하다.
V. 물음#5
1. 쟁점의 정리
행정행위의 효력유무가 형사소송의 선결문제가 되는 경우, 행정행위가 당연무효가 아닌 단순위법(취소사유)에 불과한 경우, 형사법원이 행정행위의 효력을 부인할 수 있는지가 문제된다.
2. 행정행위의 무효확인이 선결문제인 경우
구성요건적 효력은 행정행위가 무효인 경우에는 인정되지 않으므로 형사법원은 행정행위의 무효를 확인하여 무죄를 선고할 수 있다.

3. 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제인 경우
① 행정행위가 단순위법인 경우에는 형사법원은 행정행위의 구성요건적 효력으로 인해 행정행위의 효력을 부인할 수 없다고 본다. ② 판례도 취소사유의 하자를 가진 운전면허를 가지고 운전을 한 자의 운전이 무면허운전에 해당하지 않는다고 하여 부정설의 입장이다. ③ <생각건대> 행정행위의 구성요건적 효력과 현행법상 취소소송의 배타적 관할권을 고려할 때 <부정설>이 타당하다고 본다.
- 끝 -

문2) : 20점	
I. 물음#1	
1. 쟁점의 정리	
2023년까지는 매년 200명을 선발하였는데, 2024년에는 190명만 선발한 것이 불합리한 차별로서 <평등의 원칙에 반하는지>에 대해 甲의 주장의 타당성을 검토한다.	
2. 甲의 주장의 타당성 검토	
1) 평등의 원칙의 의의 및 근거	
① 불합리한 차별을 하여서는 안된다는 원칙이다. ② 이는 헌법 제11조, 행정기본법 제9조에 근거를 둔다.	
2) 요건 및 한계	
① 합리적인 이유 없이 동일한 사항을 다르게 취급하여서는 안된다. ② 단, 불법앞에 평등 요구는 고려되지 않는다.	
3. 사안의 해결	
국토교통부장관은 [감정평가법 시행령] 제10조에 따라, "감정평가관리·징계위원회가 감정평가 업무 현황,	

자격증 보유자 현황, 관련 업무 동향 등을 종합적으로 검토하여 심의한 결과"에 기초해 합리적인 이유로 선발 인원을 달리 정한 것이다. 이는 평등의 원칙에 위배되지 않으므로, <甲의 주장은 타당하지 않다.>	
II. 물음#2	
1. 쟁점의 정리	
감정평가법 시행령 제10조의 감정평가사 합격기준 해석이 사법심사가 배제되는 <판단여지>에 해당하는지가 문제된다. 따라서, ① 판단여지의 개념과 ② 판단여지와 재량의 구별논의를 한 뒤, <판단여지 여부>를 검토한다.	
2. 판단여지의 개념	
불확정개념에 대한 행정청의 평가 및 결정에 대하여 사법부가 그 정당성을 판단하는 것이 불가능하거나 합당하지 않아서 행정청의 판단을 존중해 줄 수밖에 없는 영역을 말한다.	
3. 판단여지와 재량과의 구별 논의	
1) 재량의 의미	
재량은 법률이 행정청에게 행위의 효과, 즉 행정행위	

여부나 내용에 대해 선택할 자유를 부여한 것으로, 여러 행위 중 하나를 선택할 수 있는 권리를 말한다.	
2) 학설	
① 판단여지는 법인식 문제이고, 재량은 법률효과 선택의 문제라고 보아 양자를 구별하여 판단여지를 독자적 개념으로 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과 ② 사법심사가 제한된다는 점에서 양자를 구별할 실익이 없다는 <부정설>이 대립한다.	
3) 판례	
판례는 판단여지설의 논리를 일부 수용하면서도 재량행위와 판단여지를 구분하지 않고, 긍정설이 판단여지의 영역이라 보는 문제에 대해서도 모두 재량의 문제로 보고 있다.	
4) 검토	
판단여지와 재량은 모두 사법심사가 제한된다는 점에서 <구별부정설>과 판례의 태도가 타당하다.	
III. 물음#3	
1. 재량행위에 대해 사법심리 할 수 있는 범위와 한계	

① <기속행위>는 법령상 요건 충족시 반드시 일정한 행위를 하여야 하는 법규에 대한 기속성이 있으므로 위법여부를 법원이 독자적으로 심사할 수 있다. ② 반면에 <재량행위>는 행정청에 재량권이 있으므로 법원이 독자적 결론을 도출함이 없이 행정청의 행위에 대해 <재량권의 일탈·남용>여부를 심사한다.(행정소송법 제27조)	
2. 재량행위의 일탈, 남용 여부	
재량권의 일탈, 남용 여부에 대한 심사는 ① 사실오인, ② 비례·평등의 원칙 위배, ③ 목적 위반, ④ 재량권의 불행사 또는 해태 등이 있다.	
3. 사안의 해결	
감정평가사 선발인원 결정은 법문언에 따를 때, 재량행위에 해당한다. 이에 법원의 재량의 일탈남용이 있는지에 대해서 심사를 하게 된다. 본 사안은 국토교통부장관이 선발인원을 결정함에 있어 평등의 원칙 위반이나 재량의 해태*불행사, 사실오인 등이 없이 감정평가사의 수급동향 등을 고려하여 결정하였으므로, 이에 대해서는 사법심사가 배제될 것이다.	

문3) : 15점	
I. 물음#1	
1. 하명의 개념	인간이 본래 가지는 자유로운 행동에 대하여 행정청이 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 명하는 행위를 말한다.
2. 하명의 종류	① 상대방이 일정한 행위를 적극적으로 행하여야 할 의무가 발생하는 <작위하명>과 ② 일정한 행위를 하지 않을 의무가 발생하는 <부작위하명>, ③ 일정한 급부를 해야 할 의무인 <급부하명>, ④ 행정청에 의한 강제를 감수하고 이를 수인할 의무인 <수인하명>이 있다.
3. 과징금 부과 처분이 어떠한 하명에 해당하는지 여부	과징금 부과처분은 감정평가법인등에게 일정한 급부를 해야 할 의무를 부과하는 것이므로 <급부하명>에 해당한다.

II. 물음#2	
1. 재량행위와 기속행위의 의의	① 재량행위는 행위의 요건이나 효과의 선택에 있어 행정권에 재량이 인정되는 경우를 말한다. ② 기속행위란 행정권 행사의 요건 내지 효과가 법에 일의적·확정적으로 규정되어 행정청이 법에 정해진 행위를 할 의무를 지게 되는 행위를 뜻한다.
2. 양 자의 구별실익(사법심사 방식)	① <기속행위>는 법령상 요건 충족시 반드시 일정한 행위를 하여야 하는 법규에 대한 기속성이 있으므로 그 행위의 위법여부를 법원이 독자적으로 심사할 수 있다. ② 반면에 <재량행위>는 행정청에 재량권이 있으므로 법원이 독자적 결론을 도출함이 없이 행정청의 행위에 대해 <재량권의 일탈·남용>이 있는지를 심사한다.
3. 양 자의 구별기준	1) 법문언기준설(통설 및 판례) ① 법령에서 <~하여야 한다>고 표현하면 기속행위로 보고, ② <~할 수 있다>고 표현하면 재량행위로 본다.

2) 법문언의 표현이 불분명한 경우(통설)	당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, 당해 행위 자체의 개별적 성질과 유형 등을 <종합 고려>하여 판단하여야 한다.
3) 사안의 경우(과징금부과처분)	감정평가법 제41조에서 “과징금을 부과할 수 있다”고 규정함으로써, 통설 및 판례의 법문언 기준설에 따라 <재량행위>로 본다.
- 끝 -	

문4) : 15점	
I. 강학상 허가	
1. 의의	법령에 의한 자연적 자유에 대한 일반적·상대적·잠정적 금지를 일정한 요건을 갖춘 경우에 해제하여 본래의 자유권을 회복시켜주는 것을 말한다.
2. 기속행위인지 여부	① 인간의 자유권을 공익목적상 금지하였다가 법률상 일정한 요건을 갖춘 경우에 그 제한을 해제함으로써 본래의 자유를 회복시켜 주는 행정행위이므로, 법령에 특별한 규정이 없는 한 <기속행위>로 보아야 한다. ② 다만, 허가의 요건이 불확정개념으로 규정되어 있어 행정청에게 판단여지가 인정될 수 있는 경우나, 명문의 규정이 없더라도 중대한 공익의 고려가 필요하여 이익형량이 요구되는 경우, 법령에서 재량행위로 규정한 경우에는 <재량행위>가 된다.
3. 허가의 이익	① 원칙상 허가제도를 설정하는 법규정은 <공익의 달성>을 목적으로 하고 있을 뿐 허가를 받은 자의 경

	제적인 영업상 이익을 보호하지 않으므로, 허가로 인한 이익은 <반사적 이익>에 불과한 것이 일반적이다. ②다만, 허가요건규정이 공익 뿐만 아니라 개인의 이익도 보호하고 있다고 해석되는 경우에는 허가로 인한 영업상 이익은 <법률상 이익>이 된다.
4. 무허가행위의 효과	무허가행위는 위법한 행위가 되고 통상 법률에서 그에 대하여 <행정벌을 부과>한다. 그러나 당해 무허가행위의 사법상 효력이 부인되는 것은 아니다.
II. 강학상 허가과 예외적 승인과 차이점	
1. 예외적 승인	
1) 의의	예외적 허가란 사회적으로 바람직하지 않은 일정행위를 법령상 원칙적으로 금지하고 예외적인 경우에 이러한 금지를 해제하여 당해 행위를 적법하게 할 수 있게 하여 주는 행위를 말한다.
2) 사례	토지보상법상 타인토지출입허가, 개발제한구역 내의 건축허가나 용도변경 등이 있다.

2. 양자의 차이점	①허가는 원칙적으로 <허가를 전제로 금지>하는 반면, 예외적 승인은 원칙상 <금지를 전제로 허가>를 한다. ②허가는 원칙적으로 <기속행위>인 반면, 예외적 승인은 <재량행위>인 점 등이 상이하다.
	- 끝 -

문5) : 10점	
I. 쟁점의 정리	감정평가법인의 설립행위(기본행위)에만 문제가 있는 경우 ①감정평가법인의 설립행위와 인가행위의 관계를 설명하고, ②기본행위의 하자시 쟁송방법에 대하여 검토한다.
II. 감정평가법인의 설립행위와 인가행위의 관계	
1. 인가의 의의	①행정청이 제3자의 법률행위를 동의로써 보충하여 그 행위의 효력을 완성시키는 행정행위를 말한다. ②제3자의 행위를 보충한다는 점에서 <보충행위>라고도 한다.
2. 인가와 기본행위의 관계	①인가는 기본행위의 효력을 완성시켜 주는 <보충적 행위>이므로 인가의 효력은 기본행위의 유무 및 하자에 의해 영향을 받는다. ②따라서 기본행위가 소멸되면 인가는 별도의 무효선언이나 처분청의 직권취소 없이도 실효된다.

3. 사안의 경우	기본행위의 하자의 정도에 따라 인가의 효력이 달라진다. ① 기본행위가 무효인 경우, 인가는 무효일 뿐이고 인가로 인해 기본행위가 유효하게 되는 것은 아니다. ② 기본행위가 취소사유인 경우, 기본행위가 취소되지 않는 한 인가의 효력에는 영향이 없다.
III. 쟁송방법	
1. 쟁송방법	①<기본행위에 하자>가 있는 경우 기본행위의 하자를 다투어야 하며, 기본행위의 하자를 이유로 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익은 없다. ②다만, 기본행위는 적법하나 <인가에 하자가 있는 경우>에는 인가를 대상으로 무효확인이나 그 취소를 구할 법률상 이익이 있다.
2. 사안의 경우	본 사안은 <기본행위>에만 하자가 있으므로, <기본행위의 하자>를 민사소송으로 다투어야 한다.
	- 끝 -
	-이하여백-

0기 3주차 예시답안

문 1) 40점 - 0기 3주차 예시답안	
I. 물음#1	
1. 쟁점의 정리	
사업인정에 부가된 기부채납의 조건이 어떤 부관에 해당하는지 검토한다.	
2. 부관의 개념과 종류	
1) 부관의 개념 및 기능 등	
① 부관이란 주된 행정행위의 효과를 제한 또는 보충하기 위하여 부가된 종된 규율을 말한다. ② 이는 법령의 규정에 의해 부과된 법정부관과 구별된다. ③ 부관은 행정의 유연성과 탄력성, 상황적합성을 부여해주는 기능을 한다.	
2) 부관의 종류	
① <조건>이란 행정행위의 효과의 발생 또는 소멸을 장래에 발생 여부가 불확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다. ② <기한>이란 행정행위의 효과의 발생 또는 소멸을 장래에 발생 여부가 확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다. ③ <부담>이란 행정행위의 주된 내용에 부수하여 상대방에게 작위·부작위·급부·	

수인 등의 의무를 부과하는 부관을 말한다. ④ <철회권 유보>란 일정한 경우에 행정행위를 철회하여 행정행위의 효력을 소멸시킬 수 있는 권한을 유보하는 부관을 말한다. ⑤ <법률효과의 일부배제>란 법령이 행정행위에 부여하는 효과의 일부를 배제하는 내용의 부관을 말한다.	
3) 조건과 부담의 구별	
① <정지조건부 행정행위>는 일정한 사실의 성취가 있어야 행정행위의 효력이 발생하는 반면, <부담부 행정행위>는 부담의 이행이 없어도 처음부터 효력이 발생한다는 점에 차이점이 있다.	
② 해제조건부 행정행위는 일정한 사실의 성취에 의하여 당연히 행정행위의 효력이 소멸되는데 반하여 부담은 이를 이행하지 않더라도 당연히 효력이 소멸되지 않는다는 점에서 차이점이 있다.	
③ 양자의 구별은 <행정청의 객관적인 의사>가 중요하며, ④ 부담과 조건의 구별이 애매한 경우에는 상대방에게 유리한 <부담>으로 추정한다.	

3. 사안의 경우	
국토교통부장관이 甲에게 토지를 기부채납하라는 급부 의무를 부과하였고, 그 이행 여부와 관계없이 주된 행정행위의 효력이 발생하므로, <행정청의 객관적인 의사>를 고려할 때 <부담>에 해당한다고 본다.	
II. 물음#2	
1. 시간적 한계	
1) 문제점	
행정행위를 발령한 후에 부관을 새로이 부착(사후부관)하거나 변경(사후변경)할 수 있는지가 부관의 시간적 한계로서 문제가 된다.	
2) 관련 규정(행정기본법 제17조 제3항)	
① 법률에 근거가 있는 경우, ② 당사자의 동의가 있는 경우, ③ 사정이 변경되어 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경하지 아니하면 해당 처분의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에 처분을 한 후에도 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경할 수 있다.	

3) 관련 판례	
판례는 행정기본법상 3가지 사유 이외에 사후변경이 미리 유보된 경우에도 부관의 사후변경이 가능하다고 본다.	
2. 내용상 한계(행정기본법 제17조 제4항)	
1) 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것	
주된 행정행위의 목적에 반하거나 그 본질적 효력을 해하지 않아야 한다.	
2) 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것	
부관이 주된 행정행위와 실질적 관련성이 없는 경우에는 부당결부금지의 원칙에 위반된다.	
3) 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것	
주된 행정행위의 효과를 무의미하게 만드는 경우라면 그러한 부관은 비례원칙에 위반된다.	
III. 물음#3	
1. 쟁점의 정리	
주된 행정행위와 분리하여 부관만을 소송대상으로 삼을 수 있는지가 문제된다.	

문2) : 20점
I. 쟁점의 정리
개별공시지가를 기초로 부과된 재산세에 대한 취소 청구소송에서 개별공시지가의 위법성을 주장할 수 있는지 <하자승계 여부>를 검토한다.
II. 개별공시지가와 재산세부과의 법적 성질
1. 개별공시지가의 의의 및 법적성질(부동산공시법 제10조)
①개별공시지가란 표준지의 공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 가격을 말한다. ②건해의 대립이 있으나 판례는 개별토지가격 결정은 과세의 기준이 되는 등 국민의 권리, 의무에 직접적으로 관계되는 것으로 <행정처분>에 해당한다고 판시한 바 있다. <생각건대> 과세처분의 직접적 기준이 되므로 항고쟁송으로 다룰 수 있는 것이 국민의 권리구제상 유리하다.
2. 재산세 부과와 법적 성질
재산세 부과는 A시장이 P에게 재산세의 납부의무를 명하는 행위로서 <급부 하명>에 해당한다. 따라서 당해 사안의 재산세부과처분은 <행정처분>에 해당한다.

III. 하자승계 여부
1. 하자승계의 의의 및 논의 배경
①둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우에, 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다룰 수 있는지에 대한 문제를 말한다. ②이는 법적 안정성의 요청과(불가쟁력) 국민의 권리구제의 조화의 문제이다.
2. 전제요건
1) 의의
①선행행위와 후행행위 모두 처분일 것, ②선행행위에 취소사유의 하자가 존재할 것, ③선행행위에 불가쟁력이 발생할 것, ④후행행위는 적법해야 한다.
2) 사안의 경우
①개별공시지가와 재산세 부과는 모두 <처분>에 해당하고, ②개별공시지가는 취소사유의 위법성이 있으며, ③개별공시지가의 이의신청에 대한 결과를 통지 받은 후 90일 이내에 행정제기를 하지 않아서 <불가쟁력>이 발생하였고(행정기본법 제36조 제4항), ④재산세 부과는 적법하다고 간주된다. 따라서 전제요건을 모두 충족한다.
3. 하자승계 해결논의

1) 학설
(1) 하자승계론 (전통적 견해)
① 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하고 ② 양 행위가 서로 독립하여 별개의 법적 효과를 발생시키는 경우에는 하자가 승계되지 않는다고 본다.
(2) 구속력론 (새로운 견해)
① 선행행위가 후행행위에 대하여 구속력이 미치는 객관적, 주관적, 시간적 한계내에서는 하자의 승계를 부정하는 견해이다. ② 다만, 이러한 선행행위의 구속력이 <예측가능성과 수인한도>를 벗어나는 경우에는 구속력이 차단되어 하자가 승계된다고 본다.
2) 판례
① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다. 따라서 대집행 각 절차 사이, 강제징수 각 절차 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
② 그러나 표준지공시지가와 개별공시지가 사이, 표준지공시지가와 조세부과처분 사이, 건물철거명령과 대집행 계고 사이, 사업인청과 수용재결 사이에는 하자승계를 부정하였다.

③ 다만, 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도와 예측가능성을 벗어난다면 선행처분의 구속력을 인정할 수 없다고 하여, 개별통지가 없는 개별공시지가와 과세처분, 표준지공시지가와 수용재결(보상금증감청구소송) 사이의 하자승계를 긍정하였다.
3) 검토
①하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다. ②따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계여부를 개별적·구체적으로 판단함에 타당하다.
4. 사안의 해결
P가 이의신청에 대한 결과 통지를 받고도 행정쟁송으로 다투지 않은 경우, 선행처분인 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘는 가혹한 것이거나 예측불가능하다고 볼 수 없으므로, 하자승계는 부정된다.

문3) : 20점	
I. 물음#1	
1. 직권취소의 의의 및 구별개념(행정기본법 제18조)	
① 행정행위의 취소란 일단 유효하게 성립한 행정행위를 그 성립에 있어서 위법 또는 부당의 하자가 있음을 이유로, 그 효력의 전부 또는 일부를 소멸시키는 행정청의 의사표시를 말한다. ② 취소는 독립된 새로운 행정행위이며, 성립 이후의 하자를 이유로 하는 <철회>와 구별된다.	
2. 직권취소의 제한	
1) 침익적 행정행위의 경우	
침익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 이익을 주므로 침익적 행정행위의 취소권 행사는 원칙적으로 자유롭다.	
2) 수익적 행정행위의 경우	
① 수익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 침익적 행위가 되므로 수익적 행정행위의 취소권 행사는 제한을 받는다.(행정기본법 제18조 제2항) ② 적법상태의 실현에 대한 공익과 개인의 기득권에 대한 신뢰	

보호를 비교, 형량하여 취소여부를 결정하여야 한다는 것이 학설과 판례의 태도이다. ③ 따라서 수익적 행정행위의 취소는 비례의 원칙, 신뢰보호의 원칙, 실권의 법리 등에 의해 제한받는다. ④ 처분의 하자가 수익자의 책임 있는 사유에 기인하는 경우에는 신뢰의 보호가치가 부정되어 취소가 제한되지 않는다.(행정기본법 제18조 제2항 단서)	
3) 복효적 행정행위의 경우	
위법한 복효적 행정행위의 직권취소의 경우 취소로 인한 상대방의 이익 또는 불이익과 함께 제3자의 이익 또는 불이익도 고려하여 취소여부를 결정해야 하므로 취소가 제한된다.	
3. 직권취소의 효과	
1) 침익적 행정행위의 경우	
소급효를 인정해도 일반적으로 상대방의 신뢰를 해치지 않기 때문에 소급효가 원칙이다.	
2) 수익적 행정행위의 경우	
① 상대방에게 귀책사유가 없는 한 취소의 효과가 소급하지 않는 것이 원칙이다. ② 그러나 상대방에게 귀	

책사유가 있거나 취소의 소급효를 인정하지 않으면 심히 공익에 반하는 경우에는 소급효 있는 취소가 가능하다.	
3) 복효적 행정행위의 경우	
행정행위의 상대방 및 제3자의 이익 및 귀책사유에 따라 취소의 소급효 여부 및 정도가 결정된다.	
II. 물음#2	
1. 문제점	
직권취소도 하나의 행정행위로서 그 직권취소에 하자가 있는 경우 해당 취소처분을 취소함으로써 원래의 행정행위의 효력을 회복시킬 수 있는지가 문제된다.	
2. 학설	
1) 긍정설	
취소의 취소도 행정행위인 바 원행정행위가 소생된다고 보는 견해이다.	
2) 부정설	
취소로 인해 해당 행위의 효력이 확정적으로 소멸하	

므로 명문의 규정이 없는 한 동일한 처분을 하여야 한다는 견해이다.	
3) 절충설	
원칙적으로 취소의 취소는 불가하지만, 수익적 행정행위의 취소는 위법한 취소를 취소하여 원상회복시킬 필요가 있으므로 취소의 취소를 인정하여야 한다는 견해이다.	
3. 판례	
부담적 행정행위의 경우에는 상대방의 신뢰보호이익을 위해 취소의 취소를 부정하고, 수익적 행정행위의 경우에는 제3자의 이해관계가 개입되지 않은 경우에만 한하여 취소의 취소가 가능하다고 하여, 절충설의 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.	
4. 검토	
원칙적으로 행정행위의 취소를 다시 취소하는 것은 불가하지만, 수익적 행정행위의 취소는 위법한 취소를 취소하여 원상회복시킬 필요가 있으므로 <제3자의 이해관계>가 개입되지 않은 경우에만 한하여 취소의 취소가 가능할 것이다.	- 끝 -

문4) : 15점

I. 철회의 의의 및 근거

① 적법하게 성립한 행정행위에 대해 그 효력을 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생하였음을 이유로 장래에 향하여 그의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. ② 행정기본법 제19조에서 철회의 근거를 명문화하고 있다.

II. 철회의 사유

1. 행정기본법 상의 철회사유

① 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우, ② 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우, ③ 중대한 공익을 위하여 필요한 경우에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다.

2. 학설과 판례상 철회사유

① 상대방의 법령위반이나 의무위반이 있는 경우(불법 영업으로 인한 영업취소), ② 부담 불이행의 경우(점용료 미납으로 인한 도로점용허가취소), ③ 철회권이 부관으로 유보된 경우 등을 철회의 사유로 본다.

Ⅲ. 철회의 제한

1. 침익적 행정행위의 철회

침익적 행정행위의 철회는 상대방에게 이익을 가져다주므로 별다른 제한을 받지 않고 자유롭게 할 수 있음이 원칙이다.

2. 수익적 행정행위의 철회

① 수익적 행정행위의 철회는 상대방의 신뢰와 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 철회사유가 발생한 경우에도 철회를 하여야 하는 공익상의 필요, 상대방의 신뢰, 기득권 보호, 법적 안정성의 유지 등 관련 된 모든 이익을 비교·형량하여 철회 여부를 결정하여 야 한다. ② 따라서 직권취소와 마찬가지로 비례의 원 칙이나 신뢰보호의 원칙 등을 위배하여 행한 철회는 위법한 처분이 된다.

IV. 철회의 효과

① 행정기본법 제19조 제1항에서 ‘행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다’고 규정하고 있다. ② 따라서 철회의 효과는 장래에 향하여 발생하는 것이 원칙이다.

V. 철회의 취소

① 철회에 하자가 있는 경우 이를 취소하여 본래의 행정행위를 소생시킬 수 있는지가 문제된다. ② 이는 <하자 있는 취소의 취소>와 동일한 논리가 적용된다. ③ 판례는 침익적 행정행위의 철회의 취소는 인정하지 않지만, 수익적 행정행위의 철회의 취소는 가능한 것으로 본다.

- 끝 -

문5) : 15점

I. 하자치유의 개념과 인정필요성

1. 하자치유의 개념

① 하자의 치유란 성립당시에 하자가 있는 행정행위가 사후에 하자의 원인이 되는 법률요건을 충족하였거나 또는 그 하자가 취소사유가 되지 않을 정도로 경미해진 경우에 그의 성립당시의 하자에도 불구하고 하자 없는 적법한 것으로 다루는 것을 말한다.

2. 하자치유의 인정필요성

하자의 치유는 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 인정될 수 있다.

II. 하자치유의 시간적 한계

1. 학설

1) 쟁송제기이전시설

국민의 신뢰보호와 예측 가능성을 위해 하자의 치유
는 정송제기 이전까지만 가능하다고 보는 견해이다.

2) 소송제기이전시설

행정심판의 내부통제 기능을 고려하여 소송제기 이

	전까지 가능하다고 보는 견해이다.
3) 쟁송종결이전시설	
	국민의 권리구제의 침해가 없는 경우에 쟁송종결이 전까지 허용된다고 보는 견해이다.
2. 판례	
	판례는 이유제시(부기)가 결여된 과세처분의 하자치 유와 관련하여 늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 하여야 한다고 하여, <쟁송제기이전시설>을 취하고 있다.
3. 검토	
	①소송 중 치유가 가능하다고 보는 쟁송종결이전시 설은 행정의 효율성을 일방적으로 강조하여 행정절 차가 갖는 사전권리구제의 기능과 공정한 행정의 보 장을 본질적으로 훼손시킬 우려가 있다. ②따라서 행 정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기 능 등을 종합 고려하여 쟁송제기 전까지 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.
	- 끝 -

0기 4주차 예시답안

문 1) : 35점 - 0기 4주차 예시답안	
I. 물음#1	
1. 쟁점의 정리	개발제한구역 지정(행정계획)의 처분성 여부를 검토한다.
2. 행정계획의 법적 성질	
1) 행정계획의 의의	행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현하기 위한 활동기준으로 설정된 것이다.
2) 행정계획의 종류	① 대외적으로 국민에 대하여 일정한 법적 효과를 발생시키는 <구속적 행정계획>과 ② 행정기관의 내부지침에 불과하여 국민이나 행정기관 어느 쪽에도 구속력을 갖지 않는 <비구속적 행정계획>이 있다.
3) 법적성질(처분성 여부)	

(1) 학설	① 행정계획은 일반적·추상적 규율로서 입법의 성질을 가진다고 보는 <입법행위설>, ② 특정인의 권리나 법률상 이익에 개별적이고 구체적인 변동을 초래하므로 행정행위의 성질을 가진다고 보는 <행정행위설>, ③ 행정계획은 그 종류가 다양하고 형태도 여러 가지이므로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 <개별검토설>, ④ 행정계획은 규범도 아니고 행정행위도 아닌 독자적인 성질을 가진다고 보는 <독자성설>이 있다.
(2) 판례	① 도시·군기본계획에 대해서는 행정활동의 지침으로서의 성격만을 갖는바 처분성을 부정하였으나, ② 도시·군관리계획과 주택재건축정비사업조합의 사업시행계획이나 관리처분계획은 국민의 권리·의무에 구체적으로 직접 영향을 미치므로 처분성을 인정하였다. ③ 최근 <4대강 살리기 마스터플랜> 등은 4대강 살리기 사업의 기본방향을 제시하는 계획으로서, 행정처분에 해당하지 않는다고 하였다.
(3) 검토	

행정계획은 그 종류와 내용이 매우 다양하고 상이하므로, 행정계획의 법적 성질은 각 계획이 갖는 목적과 내용을 기준하여 <개별적으로 검토>하여야 할 것이다.	
3. 사안의 해결	① 개발제한구역 지정으로 인하여 甲토지에 건축물의 건축이 불가능하고 토지의 형질 변경에 제한을 받으므로 <구속적 행정계획>에 해당하며, ② 甲의 권리·의무에 구체적으로 직접 영향을 미치므로 처분성이 인정된다.
II. 물음#2	
1. 계획재량의 의의	① 계획재량이란 행정주체(계획청)가 행정계획의 수립·변경과정에서 갖게 되는 광범위한 형성의 자유를 의미한다. ② 계획재량은 행정목표의 설정이나 행정목표를 효과적으로 달성할 수 있는 수단의 선택 및 조정에 있어서 인정된다.
2. 계획재량과 행정재량과의 구분	
1) 학설	

(1) 구별긍정설(다수설)	계획재량은 목적과 수단으로 구성되었으나 재량행위는 요건과 효과로 구성되어 양자는 규범구조가 서로 다르고, 계획재량에는 형량명령이라는 고유한 하자이론이 존재하여 질적 차이가 있다고 본다.
(2) 구별부정설	규범구조의 차이는 본질적인 것이 아니고, 형량명령도 비례의 원칙의 내용에 해당하는 법원리라고 보아 질적 차이를 부정하고 양적 차이만을 인정하는 견해이다.
2) 판례	① 종래에는 계획재량의 하자과 관련하여 재량권의 일탈·남용으로 사안을 해결하였는데, ② 최근에는 <형량하자>라는 용어를 사용하여 계획재량의 독자성을 나타내는 경향을 보이고 있다.
3) 검토	① 계획재량은 행정재량에 비해 비교적 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 보는 것이 일반적이다. ② 또한 양자는 규범구조 및 하자이론의 구성에 있어서

	차이가 있기 때문에, <양자를 구별>하는 것이 타당하다.
III	물음#3
1.	계획재량의 한계
	① 행정계획을 수립함에 있어서는 계획청에게 계획재량이 인정되는데, 이러한 계획재량은 무제한적인 것이 아니라 일정한 한계를 가진다. ② 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며, ③ 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다. ④ 또한 필요한 수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다(형량명령).
2.	형량명령의 준수
	① 형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙으로서 계획재량의 통제이론이다. ② 행정계획결정이 형량명령의 내용에 반하는 경우에는 형량하자가 있게 된다. ③ 형량하자가 발생한 경우 당해 행정계획은 위법하게 된다.
3.	형량하자

	① 형량을 전혀 하지 않은 경우(형량의 해태) ② 형량의 대상에 마땅히 포함되어야 할 사항을 빠뜨린 경우(형량의 흠결) ③ 관련된 공익과 사익의 가치를 잘못 평가한 경우(형량의 과오) ④ 이익형량을 행하긴 하였으나 그것이 객관성·비례성을 결하는 경우(오형량)에는 그 행정계획 결정은 형량에 하자가 있어서 위법하게 된다고 판시한 바 있다.
IV	물음#4
1.	계획변경청구권의 의의
	계획이 확정된 후 사정변경 및 관련 개인의 권익침해 등을 이유로 하여 그 계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 의미한다.
2.	계획변경청구권의 인정여부
	① 계획법규는 원칙상 <공익의 보호를 목적>으로 하는 것이며 사익의 보호를 목적으로 하지 않기 때문에, 이러한 계획변경청구권은 일반적으로 인정되지 않는다. ② 그러나, 예외적으로 법규상 또는 조리상 계획변경신청권이 인정되는 경우에는 해당 계획의 변경을 청구할 수 있을 것이다.

3.	관련 판례
	판례는 과거 계획변경청구권을 일반적으로 인정하지 않았으나, 최근에는 긍정적인 입장을 취하고 있다. 폐기물처리사업계획의 적정통보를 받은 자의 국토이용계획변경신청(용도지역 변경)을 거부하는 것이 실질적으로 폐기물처리업허가 자체를 거부하는 결과가 되는 경우, 예외적으로 그 신청인에게 법규상 또는 조리상 행정계획변경을 신청할 권리를 인정하여 신청거부행위의 처분성을 긍정하였다.
4.	사안의 해결
	① 甲의 청구가 받아들여지기 위해서는 계획의 변경을 청구하는 자의 개인적 이익이 계획법규에 의해 보호되고 있어야 하고, 행정청에게 계획변경의무가 있어야 한다. 그러나 ② 계획법규는 공익달성을 목적으로 하며, 계획변경을 구하는 甲의 사익이 계획존속에 대한 공익보다 크다고 보기 어려워 甲의 청구는 받아들여지지 않을 것이다.
	- 끝 -

	문2) : 30점
I	물음#1
1.	쟁점의 정리
	감정평가사의 갱신등록 신청에 대하여 거부처분을 하면서 사전통지를 하지 않은 경우 거부처분이 위법한지 검토한다.
2.	거부처분의 의의 및 구별개념
	① 거부처분이란 공권력 행사의 신청에 대해 처분의 발령을 거부하는 행정청의 의사작용으로서, ② 거절의사가 명확한 점에서 아무런 처분을 하지 않는 <부작위>와 구별된다.
3.	거부처분시 사전통지의 대상인지 여부
	1) 사전통지의 의의 및 취지(행정절차법 제21조)
	① 사전통지란 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전에 통지하는 것을 말한다. ② 사전통지는 의견진술의 전치절차로서, 당사자에게 불이익처분을 하기 전에 의견제출의 기회를 주려는데 의의가 있다.

2) 사전통지의 생략 사유(행정절차법 제21조 제4항)
① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 생략 가능하다.
3) 거부처분의 사전통지
(1) 문제점
사전통지의 적용 범위와 관련하여 <수익적 행정처분의 신청을 거부>하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인지가 문제 된다.
(2) 학설
① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 그 거부하는 권익을 제한하는 처분이 아니므로 사전통지가 불필요하다고 보는 <부정설>, ② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부는 기대이익을 제

한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <긍정설> ③ 원칙적으로는 부정하나, 인허가에 부가된 갱신기간의 경우는 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 것으로 보아 <제한적 긍정설>이 있다.
(3) 판례
판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그 거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.
(4) 검토
① 원칙적으로 신청의 거부는 권익제한이 아니라고 판단된다. ② 다만, 인허가 갱신의 경우는 갱신에 의해 종전의 허가효과가 유지되는 바, 이는 권익 제한에 해당한다고 볼 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다고 본다.
4. 사안의 해결
① 감정평가사 甲의 갱신 등록은 갱신에 의해 종전의 감정평가업을 할 수 있는 효과가 유지하므로 이

는 권익 제한에 해당한다고 볼 수 있으므로 사전통지 결여는 <위법>하다고 본다. ② 다만, 판례의 입장에 따르면 거부처분시 사전통지 결여는 <위법하지 않다고 본다.>
II. 물음#2
1. 쟁점의 정리
① 거부처분을 하면서 이유제시를 하지 않은 경우 절차상 하자에 해당하는지 검토하고, ② 절차상 하자의 독자적 위법사유의 인정여부를 논한다.
2. 거부처분시 이유제시 결여가 절차상 하자인지 여부
1) 이유제시의 의의 및 취지
① 이유제시란 행정청이 처분을 할 때에 당사자에게 그 근거와 이유를 알려주는 것을 말한다. ② 처분의 당사자등에게 처분의 적법성과 사후불복절차를 알려주어 (a)법원의 부담을 경감시키고 (b)행정청에게는 자의를 배제하고 신중한 처분을 하도록 하고 (c)처분의 결정과정을 보다 투명하게 한다.
2) 필수 절차인지 여부
① 신청 내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우,

② 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우, ③ 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우를 제외하고는 당사자에게 <모든 처분>에 그 근거와 이유를 제시하여야 한다. (행정절차법 제23조 제1항)
3) 이유제시의 정도 및 하자
① 면허취소와 같은 <적극적 처분>의 경우 이유제시는 당사자가 당해 처분의 근거법령과 처분사유를 이해할 수 있을 정도로 구체적이고 상세하게 적시되어야 한다. ② 반면, 인허가 등을 거부하는 <소극적 처분>의 경우에는 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우라면, 구체적인 법조항 및 내용까지 명시하지 않더라도 위법하지 않는 것이 판례의 입장이다.
4) 사안의 경우
① 본 사안은 이유제시를 생략할 수 있는 경우에 해당하지 않으므로, 국토교통부장관은 <이유제시>를 필수로 하여야 한다. ② 따라서 이유제시를 결여한 거부처분은 <절차상 하자>가 있다.

3. 절차상 하자의 독자적 위법사유 인정 논의
1) 문제점
실체법상 적법함에도 불구하고 절차상 하자를 독자적 위법사유로 삼을 수 있는지 문제된다.
2) 학설
① 적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 기속력을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 <긍정설>, ② 행정절차는 적정한 행정결정을 위한 수단에 불과하고, 절차상 하자를 이유로 취소하더라도 행정청을 그 적정한 절차를 거쳐 동일한 처분을 할 수 있으므로 소송경제상 부정하는 <부정설>, ③ 재량행위와 기속행위를 나누어 재량행위의 경우는 행정청의 선택이 변경가능한 바 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위의 경우는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법한 것은 아니라고 보는 <절충설>이 있다.
3) 판례

① 판례는 재량행위나 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자를 독자적 취소사유로 보는 적극설의 입장이다. ② 재량행위인 식품위생법상 영업정지처분에 절차상 하자가 있는 경우 위법하다고 판시하였다. ③ 기속행위인 과세처분 또한 절차상 하자가 있으면 위법하다고 판시하였다.
4) 검토
① 행정작용은 법률적합성의 원칙에 따라 그 내용(실체)뿐 아니라 절차도 적법하여야 한다. ② 또한, 행정소송법 제30조 제3항에서 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 판례와 같이 적극설이 타당하다.
- 끝 -

문3) : 15점
I. 행정상 사실행위의 종류
1. 행정상 사실행위의 의의
일정한 법적 효과의 발생을 직접적 목적으로 하는 행위가 아니라, 일정한 사실상의 결과발생만을 목적으로 하는 행정주체의 일체의 행위를 말한다.
2. 사실행위의 종류
1) 권력적 사실행위
① 행정주체가 우월적 지위를 가지고 하는 사실행위로, 공권력 행사의 실체를 가지는 사실행위를 말한다. ② 예로 행정대집행의 실행, 행정상 즉시강제, 권력적 행정조사 등이 있다.
2) 비권력적 사실행위
① 공권력 행사의 실체를 갖지 않는 사실행위를 말한다. ② 예로 상담, 안내, 행정지도, 여론조사 등이 있다.
II. 위법한 사실행위가 발생시 가능한 권리구제 방법
1. 항고쟁송

1) 비권력적 사실행위
처분성이 결여되어 원칙적으로 항고쟁송의 대상이 되지 않는다.
2) 권력적 사실행위
① 권력적 사실행위는 일반적으로 처분성이 인정된다고 본다 ② 그러나 권력적 사실행위의 대부분은 단기간에 집행이 종료되는 경우가 보통이므로 행정쟁송이 제기되더라도 권리보호의 필요(협약의 소익)이 결여되어 각하재결이나 각하판결을 받게 될 가능성이 높다. ③ 판례는 계속적 성질을 갖는 권력적 사실행위로 볼 수 있는 단수조치, 교도소 재소자의 이송조치 등에 대해서 처분성을 인정하였다.
2. 헌법소원
1) 비권력적 사실행위
비권력적 사실행위가 국민의 기본권에 직접 영향을 미치는 경우에는 헌법소원의 대상이 된다고 한다.
2) 권력적 사실행위
헌재는 권력적 사실행위의 처분성을 인정하면서도 권력적 사실행위가 소의 이익이 없어 법원에 의한

	구제를 받을 수 없을 경우 보충성 원칙에 대한 예외에 대하여 헌법소원의 대상이 된다고 보고 있다.
3. 행정상의 손해전보와 결과제거청구	
1) 손해배상청구	위법한 사실행위로 인하여 손해가 발생한 경우 국가배상청구가 가능하다.
2) 결과제거청구	행정상 사실행위로 위법한 상태가 초래되어 권리가 침해되는 경우에는 행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 당사자소송에 의해 결과제거청구를 할 수 있다.
3) 손실보상청구	적법한 사실행위로 인하여 개인의 재산권에 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상을 청구할 수 있다.
	- 끝 -

문4) : 10점	
I. 청문의 의의 및 취지(행정절차법 제22조)	
① 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다.	
② 청문은 행정처분을 함에 있어 당사자의 절차적 참여를 보장하고, 의견제출의 기회를 부여하여 국민의 방어권을 보호함에 그 취지가 인정된다.	
II. 청문 절차 생략 사유(행정절차법 제22조 제4항)	
1. 생략 사유	
① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정된 경우, ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한 경우에는 생략 할 수 있다.	

2. 관련 판례	
① <의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우>란 해당 행정처분의 성질에 비추어 판단하여야 하며, ② 행정처분의 상대방이 청문일시에 불출석하였다는 이유로 청문을 실시하지 아니하고 한 침해적 행정처분은 위법하고, ③ 협약으로 의견청취절차를 배제하는 조항을 두었다고 하더라도 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당한다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.	
III. 청문 절차	
1. 실시요건(행정절차법 제22조 제1항)	
① 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우, ② 행정청이 필요하다고 인정하는 경우, ③ 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이거나 조합 등의 설립허가의 취소등의 처분을 하는 경우에는 청문을 하여야 한다.	
2. 청문의 사전통지	
행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 제1항 각 호의 사항(처분의 사전통지)을	

당사자등에게 통지하여야 한다.(행정절차법 제21조 제2항)	
3. 청문의 진행 및 종결 등	
① 청문 주재자가 청문을 시작할 때에는 먼저 예정된 처분의 내용, 그 원인이 되는 사실 및 법적 근거 등을 설명하여야 하고, ② 청문 주재자는 해당 사안에 대하여 당사자등의 의견진술, 증거조사가 충분히 이루어졌다고 인정하는 경우에는 청문을 마칠 수 있다. ③ 행정청은 처분을 할 때에 청문 조서를 검토하고 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 청문결과를 반영하여야 한다.	
- 끝 -	

문5) : 10점	
I. 확약의 의의	
① 장래 일정한 행정행위를 하거나 하지 아니할 것을 약속하는 의사표시를 말한다. ② 확약은 신뢰보호 또는 금반언의 법리를 바탕으로 인정되는 행정청의 행위형식의 하나이다.	
II. 법적근거	
① 행정절차법 제40조의2 제1항에서는 신청에 따른 확약의 법적근거를 규정하고 있다. ② 학설은 대체로 행정청의 처분권한에 확약의 권한도 포함되어 있다고 본다.	
III. 법적성질 (처분성 여부)	
1. 학설	
1) 긍정설	
확약이 행정청에 대하여 확약의 내용대로 이행할 법적 의무를 발생시킨다는 점에 비추어 확약의 처분성을 인정하는 견해이다.	

2) 부정설	
확약은 사정변경에 의해 변경될 수 있으므로 중국적 규율성을 가지지 못한다는 점을 근거로 처분성을 부정하는 견해이다.	
2. 판례	
판례는 <어업권 우선순위결정>을 확약으로 보면서 이는 행정처분이 아니므로 공정력, 불가쟁력 등과 같은 효력이 인정되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다. 그러나 일부 판례에서는 내인가취소를 구분처분으로 보아 처분성을 인정한 사례도 있다.	
3. 검토	
확약으로 행정청에게 확약을 준수할 의무가 발생하는 점, 확약의 처분성을 인정함으로써 조기에 권리구제를 도모할 수 있다는 점을 고려하여 확약의 처분성을 인정하는 것이 타당하다.	
- 끝 -	
- 이하여백 -	

0기 5주차 예시답안

문 1) : 40점 - 0기 5주차 예시답안
I. 물음#1
1. 대집행의 의의 및 근거
① 공법상 대체적 작위의무의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다. ② 대집행의 일반법으로 행정대집행법이 있다.
2. 대집행의 요건(행정대집행법 제2조)
1) 공법상 의무의 불이행
① 대집행의 대상이 되는 의무는 공법상의 의무이다.
② 사법상의 의무는 법령에 특별한 규정이 없는 한 대집행의 대상이 되지 않는다.
2) 대체적 작위의무의 불이행
① 대체적 작위의무란 누구나 이행이 가능하여 타인이 대신 행할 수 있는 의무를 말한다. ② 토지·건물의 인도 의무에서 사람이 그 인도·이전을 거부한다면 이는 사람을 실력으로 배제해야 하는 것이므로 대집행의 대상이 될 수 없다.

3) 다른 수단으로 그 이행을 확보하기가 곤란할 것
① 행정지도 등 의무이행을 확보할 수 있는 다른 수단이 있는 경우에는 대집행이 허용되지 않는다. ② 여기에서 다른 수단이란 비례의 원칙이 적용되는 것으로 대집행보다 경미한 수단을 의미한다.
4) 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것
① 이는 비례의 원칙 중 협의의 비례의 원칙을 의미하는 것으로, 구체적 상황 등을 고려하여 개별적으로 판단해야 한다. ② 이 요건에 대한 판단은 계고처분당시를 기준으로 판단한다.
II. 물음#2
1. 계고
1) 의의
계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 한다는 뜻을 문서로써 알리는 행위를 말한다.
2) 생략가능성(행정대집행법 제3조 제3항)
비상시 또는 위험이 절박한 경우에 계고절차를 거치지 않고 대집행을 할 수 있다.

2. 대집행 영장에 의한 통지
1) 의의 및 법적성질
① 의무자가 계고를 받고도 지정된 기한까지 그 의무를 이행하지 않을 때, 당해 행정청이 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행책임자의 성명 및 대집행비용의 개산액을 의무자에게 알리는 것을 말한다. ② 이는 준법률행위적 행정행위인 통지로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.
2) 생략가능성 (「행정대집행법」 제3조 제3항)
계고와 마찬가지로 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 통지 절차를 생략할 수 있다.
3. 대집행의 실행 의의 및 성질
① 의무자가 지정된 기한까지 의무를 이행하지 않는 경우에 당해 행정청 스스로 또는 제3자로 하여금 그 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. ② 이는 수인하명과 사실행위가 결합된 합성행위의 성질을 가지는 권력적 사실행위로서 행정처분에 해당한다.
4. 비용징수 의의 및 법적성질 등
① 대집행에 소요된 비용을 의무자에게 명령하여 징

수하는 절차이다. ② 비용납부명령은 급부하명이며 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 된다. ③ 의무자가 비용을 납부하지 않는 경우에는 국세징수법에 따라 강제징수 할 수 있다.
III. 물음#3
1. 쟁점의 정리
① 계고의 처분성 여부를 설명하고 ② 1차계고와 2차, 3차 계고 중 소송의 대상이 되는 계고가 무엇인지 검토한다.
2. 계고의 법적성질
행정대집행법 제3조 제2항에 따라 계고가 이루어지면 행정청은 대집행영장을 발급할 권한을 얻게 된다. 따라서 계고의 법적 성질은 준법률행위적 행정행위 중 <통지>에 해당하며, <항고소송의 대상>이 된다.
3. 소송의 대상이 되는 계고
1) 관련 판례
행정대집행법상의 건물철거의무는 제1차 철거명령 및 계고처분으로서 발생하였고 제2차, 제3차의 계고처분은 새로운 철거의무를 부과한 것이 아니고 다만

대집행기한의 연기통지에 불과하므로 행정처분이 아니라고 판시하였다.
2) 검토
취소소송의 대상이 되기 위해서는 국민의 권리, 의무에 영향을 주는 법적 행위이어야 한다. 하지만 2차, 3차 계고는 1차 계고와 동일한 내용을 담고 있으므로 국민의 권리, 의무에 개별적, 구체적으로 영향을 주는 법적 행위라 볼 수 없다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.
4. 사안의 해결
甲은 처분인 <1차 계고를 대상>으로 취소소송을 제기하여야 한다.
IV. 물음 #4
1. 쟁점의 정리
대집행이 실행되는 과정에서 甲이 수인의무를 위반하여 저항하는 경우, 행정청이 이를 실력으로 배제할 수 있는지 검토한다.
2. 학설

1) 긍정설
대집행에 필요한 최소한의 한도 내에서 부득이한 경우에 실력으로 그 저항을 배제할 수 있다고 본다.
2) 부정설
저항을 실력으로 배제하는 것은 대집행에 내재하는 당연한 권능으로 볼 수 없으므로 실력행사를 위해서는 법적 근거가 있어야 한다고 본다.
3. 판례
판례는 건물철거의무에 퇴거의무도 포함되어 있다고 보아 건물철거 대집행 과정에서 부수적으로 건물의 점유자들에 대한 퇴거 조치를 할 수 있고, 점유자들이 적법한 행정대집행을 위력으로 방해하는 경우 공무집행방해죄가 성립하므로 경찰의 도움을 받을 수 있다고 본다.
4. 검토
신체에 대한 실력행사는 명문에 근거가 있어야 하고, 경찰관직무집행법 등에 따른 경찰권의 발동으로 저항이 배제될 수 있으므로 <부정설>이 타당하다.

5. 사안의 해결
행정대집행을 실행하는 과정에서 甲이 이행을 거부하는 경우 행정청은 명문의 근거가 없는 바 <실력행사가 불가>하다고 본다.
- 끝 -

문2) : 30점
I. 물음 #1
1. 과징금의 의의 및 근거
① 과징금이란 행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. ② 행정기본법 제28조에 근거가 있으며, 감정평가법 제41조 내지 제44조 등 개별법에서 그 근거를 두고 있다.
2. 종류
1) 본래적 과징금
① 본래적 의미의 과징금은 행정법상의 의무위반으로 인하여 얻은 경제적 이익을 박탈하는 금전적 제재를 말한다. ② 따라서 과징금 액수는 이득액의 규모 등과 상호 균형을 이룰 것이 요구된다는 것이 판례의 입장이다.
2) 변형된 과징금
① 변형된 과징금이란 영업정지 등에 갈음하여 과징금을 부과하는 것을 말한다. ② 즉, 의무위반행위가

사업의 인허가 등을 철회하거나 정지시킬 사유에 해당하지만, 그 사업을 철회·정지시킬 경우 초래되는 공익 또는 사익의 침해를 이유로 정지 등의 처분 대신에 과징금을 부과하는 것을 말한다. ③ 감정평가법 제41조의 과징금이 여기에 해당한다.
3. 법적성질 (처분, 재량행위)
① 과징금부과행위는 행정행위로서 급부하명의 성격을 가지며 행정소송의 대상이 되는 처분이다. ② 영업정지처분을 할 것인지 과징금을 부과할 것인지는 행정청의 재량에 속하는 것으로 본다. ③ 감정평가법 제41조 제1항에서도 ‘~부과할 수 있다’고 규정하여 문언상 <재량행위>로 볼 수 있다.
Ⅱ. 물음#2
1. 甲이 과징금 납부하지 않을 경우 제재수단
1) 강제징수
① 과징금 부과처분을 받은 자가 납부의무를 불이행한 경우에는 [국세징수법] 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 강제징수할 수 있다. ② 감정평가법 제44조 제2항에는 국세체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다고 규정한다.

2) 가산금 징수
① 가산금이란 행정법상 급부의무 불이행에 대하여 과해지는 금전상의 제재이다. ② 감정평가법 제44조 제1항에 과징금 납부기한 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대해서 <가산금을 징수>할 수 있다고 규정한다.
2. 위법한 과징금에 대한 구제
1) 행정쟁송
과징금 부과행위는 침익적 행정행위(급부하명)으로서 행정쟁송법상의 처분에 해당하므로 행정심판이나 행정소송을 제기하여 그 취소를 구할 수 있다.
2) 국가배상
위법한 과징금부과처분으로서 인해 손해를 입은 자는 국가를 상대로 손해배상청구를 할 수 있으므로, 과징금이 법률상 원인 없이 징수된 경우 공법상의 부당이득반환청구를 행사할 수 있다.
Ⅲ. 물음#3
1. 쟁점의 정리

① 헌법 제13조 제1항에서는 ‘~동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다’고 규정하고 있다. ② 따라서 국토교통부장관이 동일한 위반행위에 대해 행정벌과 과징금을 병과하는 것이 이중처벌금지 원칙에 반하는 것이 아닌지가 문제 된다.
2. 학설
① 행정벌과 과징금은 그 성질과 목적에 차이가 있어 병과가 이중처벌금지 원칙에 반하는 것은 아니라고 보는 견해와 ② 동일한 위반행위에 대한 제재로 보아 과징금 등이 다른 법적 형식을 취하고 있더라도 병과가 불가능하다고 보는 견해가 있다.
3. 판례
부당내부거래에 대한 과징금은 형사처벌과 아울러 병과가 가능하며 이중처벌금지 원칙에 위반되지 않는다고 판시하였다.
4. 검토
과징금은 행정상 제재금이고, 범죄에 대한 국가의 형벌권의 실행으로서의 과벌이 아니므로 양자는 병과가 가능하다고 보는 것이 타당하다.

5. 사안의 해결
국토교통부장관이 과징금과 벌금을 중복 부과하더라도 이는 헌법 제13조의 이중처벌금지 규정에 위배되지 않으므로, 중복 부과는 가능하다.
- 끝 -

문3) : 20점	
I. 물음#1	
1. 쟁점의 정리	
① 토지보상법 제9조의 타인점유 토지에 출입하여 측량*조사 행위의 법적성질을 설명하고, ② 점유자가 조사를 거부하거나 방해할 경우 실력으로 강제조사할 수 있는지 검토한다.	
2. 타인토지출입 측량, 조사의 법적성질	
1) 의의	공익사업의 준비를 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량, 조사하는 행위를 말한다.
2) 법적 성질	① 행정기관이 행정작용을 위해 필요한 정보나 자료 등을 수집하는 일체의 행정활동으로서 <행정조사>에 해당한다. ② 행정기관이 일방적인 명령과 강제를 수단으로 하고, 토지보상법 제11조에서 점유자의 인용의무가 규정되어 있으므로 이는 <권력적 행정조사>에 해당한다.

3. 행정조사시 실력행사 가능성	
1) 학설	
(1) 긍정설	조사의 거부*방해가 있는 경우에 대한 제재 규정이 있는 것은 거부*방해 등이 위법하다는 것을 전제한 것이므로 비례의 원칙 내에서 실력행사가 가능하다고 본다.
(2) 부정설	제재규정은 간접적인 실효성 확보 수단에 불과하므로 실력행사는 허용되지 않는다고 본다.
(3) 제한적 긍정설	원칙적으로는 허용되지 않으나 예외적으로 행정조사의 필요성이 긴급하고, 다른 수단이 없는 경우에 한하여 허용된다고 본다.
2) 검토	국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 것은 명문의 근거가 없는 한 법치주의 관점에서 인정될 수 없으므로 <부정설>이 타당하다.

4. 사안의 해결	토지보상법에는 행정조사 거부나 방해가 있더라도 실력으로 강제조사를 할 수 있다는 명문의 근거가 없으므로, 강제조사는 허용되지 않는다.
II. 물음#2	
1. 쟁점의 정리	타인의 토지에 출입하면서 통지의무를 이행하지 않아 위법한 경우, 이를 근거로 한 사업인정의 위법성을 검토한다.
2. 사업인정의 의의 및 법적성질(토지보상법 제20조)	① 사업인정은 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.(동법 제2조 제7호) ② 판례는 사업인정은 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 강학상 특허로서, 처분에 해당한다.
3. 위법한 행정조사에 기한 행정행위의 효력	
1) 학설	① 적법절차의 원칙에 비취 위법한 행정조사에 기초한 행정행위는 위법하다고 보는 <적극설>, ② 행정

조사와 행정행위는 서로 별개의 제도이므로 조사의 위법이 곧바로 행정행위를 위법하게 만들지는 않는다고 보는 <소극설>, ③ 행정조사에 중대한 위법사유가 있다면 행정행위도 위법하다고 보는 <절충설>이 있다.	
2) 판례	판례는 적극설에 따라 위법한 세무조사에 기한 과세처분은 위법하다고 하였다. 다만, 행정조사의 하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본 판례도 있다.
3) 검토	① 적법절차의 원칙에 따라 행정결정은 적법하고 정당한 절차를 거쳐야 한다. ② 따라서 위법한 행정조사에 기초한 행정결정은 위법하다고 보는 <적극설>이 타당하다.
4. 사안의 해결	위법한 타인토지출입 측량, 조사 행위에 기초한 사업인정은 위법하다고 본다.
- 끝 -	

문4) : 10점	
I. 명단의 공표의 의의	
명단의 공표란 행정법상의 의무 위반 또는 의무불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가함으로써 심리적인 압박을 가하여 행정법상의 의무이행을 확보하는 간접강제수단을 말한다.	
II. 법적 근거	
① 행정법상의 의무위반자의 명단을 공표하는 것은 그의 명예, 신용 또는 프라이버시에 대한 침해를 초래하므로 명시적인 법적근거가 요구된다. ② 감정평가법 제39조의2에서 징계의 공고가 명단의 공표에 해당한다.	
III. 법적성질	
1. 학설	
① 명단공표는 수인의무를 수반하지 않으므로 비권력적 사실행위라고 보는 견해이다.(비권력적 사실행위설, 다수설), ② 공표행위는 일방적으로 행해지고 그로 인하여 명예, 신용 등이 침해되므로 권력적 사	

실행위로 보는 견해이다.(권력적 사실행위설), ③ 공표에 앞서 공표결정이 통보되는 경우에는 공표결정 통보는 행정처분의 성격을 갖고 공표 자체는 사실행위의 성격을 갖는 반면, 공표에 앞서 공표결정이 통보되지 않는 경우에는 공표는 권력적 사실행위라고 보는 견해가 있다.	
2. 판례	
판례는 병무청장이 병역의무 기피자의 인적사항 등을 인터넷 홈페이지에 게시한 것을 항고소송의 대상인 행정처분으로 판시하였다.	
3. 검토	
① 원칙적으로 명단을 공개하는 행위 그 자체는 순수한 사실행위일 뿐이므로 처분성이 부정된다. ② 그러나 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정하여 행정쟁송으로 다룰 수 있게 함이 타당하다.	
- 끝 -	
- 이하여백 -	

0기 6주차 예시답안

문 1) : 25점 - 0기 법규스터디 6주차 예시답안
I. 물음#1
1. 신고의 의의
① 신고란 사인이 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체에 대하여 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다. ② 아무런 법적 효과를 가져오지 않는 신고는 단순한 사실로서의 신고일 뿐이고, 사인의 공법행위로서의 신고에 해당하지 않는다.
2. 신고의 종류
1) 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)
신고의 요건을 갖춘 신고만 하면 신고의무를 이행한 것이 되는 신고를 말한다.
2) 행위요건적 신고(수리를 요하는 신고)
① 행정청에 대하여 일정한 사항을 통지하고 행정청이 이를 수리함으로써 법적효과가 발생하는 신고를 말한다. ② 신고의 요건을 갖춘 신고가 있었다 하더라도 수리되지 않으면 신고가 되지 않는 것으로 보는 것이 통설 및 판례의 입장이다.

3. 구별실익
① 자기완결적 신고의 수리는 단순한 접수행위이므로 법적 효과를 발생시키지 않는 사실행위이다. ② 수리를 요하는 신고에 대해 수리가 거부되면, 그 신고는 성립하지 않는 것으로 간주된다. 이는 국민의 권리와 의무에 직접적인 영향을 미치므로 <처분>에 해당한다.
II. 물음#2
1. 관련 규정
행정기본법 제34조에서는 관련 법령에서 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있으면 수리를 요하는 신고로 보고, 그렇지 않으면 수리를 요하지 않는 신고로 본다.
2. 구별이 명확하지 않은 경우
1) 학설
① 신고 요건이 형식적 요건만을 요구하는 경우에는 자기완결적 신고로 보고, 실질적 요건도 포함하는 경우 수리를 요하는 신고로 보는 <신고요건기준설>, ② 입법자의 객관적 의사 즉 당해 법령의 목적과 당해 법령에서 나타나고 있는 관련 조문에 관한 합리

적이고 유기적인 해석을 통해 구별해야한다는 견해인 <입법자의사설>, ③ 신고 요건에 대한 심사방식이 형식적 심사만 하는 신고는 자기완결적신고, 실질적 심사를 할 수 있는 신고는 수리를 요하는 신고로 보는 견해인 <심사방식기준설>, ④ 일반적인 구별기준은 관련 법규정에 의해 추론되는 입법자의 객관적 의사라고 보면서도 복수의 구체적인 구별기준을 유형화하여 제시하는 견해인 <복수기준설> 등이 대립한다.
2) 판례
판례는 관련 법규정에 따르되 기본적으로 신고요건 및 심사방식을 기준으로 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고를 구별하고 있다고 보는 것이 타당하다.
3) 검토
① 형식적 요건만이 신고요건인 신고는 <자기완결적 신고>로 보되, ② 형식적 요건 뿐 아니라 실체적 요건이 신고요건이고 실체적 요건에 대해 실질적 심사를 거치는 경우에는 <수리를 요하는 신고>로 보아야 한다. ③ 따라서, 소속 감정평가사의 고용신고는 동법 제17조상의 등록과 달리 등록거부사유에 해당하

는지 확인없이, 형식적 요건만을 요구하므로 <자기완결적 신고>에 해당한다.
III. 물음#3
1. 쟁점의 정리
감정평가사 신고를 자기완결적 신고로 볼 때, 그 수리 거부와 취소소송의 대상인 처분에 해당하는지 검토한다.
2. 학설
① 신고의 법적성질에 따라 구분하는 견해로서 자기완결적 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 되지 않고, 수리를 요하는 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 된다고 보는 견해와 ② 신고의 법적성질과 관계 없이 수리가 반려될 경우 신고인이 불이익을 받을 위험 등 법적 지위가 불안정하게 될 수 있는지 여부를 기준으로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 견해가 있다.
3. 판례
① 종래에는 신고의 법적성질을 기준으로 수리를 요하는 신고의 수리거부만이 항고소송의 대상이 된다

	고 보았으나, ② 최근 「건축법상」 신고와 관련하여 건축신고를 자기완결적 신고로 보면서도, 건축신고가 반려될 경우 당사자에게 제재적 처분이 내려질 우려가 있어 불안정한 지위에 놓이게 된다고 보아, 건축신고 반려행위를 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보아 개별적으로 검토하는 견해를 취하고 있다.
4. 검토	신고의 법적성질을 기준으로 하는 견해는 국민의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 미신고행위에 대한 제재규정이 있다면 이는 사인에게 신고의무를 지우는 것으로서 그러한 신고에 대한 수리거부의 처분성을 긍정함이 타당하다.
5. 사안의 해결	감정평가사 乙의 신고는 법적 성질과 관계없이 수리거부될 경우, 감정평가사 甲은 [감정평가법] 제50조에 따라 벌금 부과 위험 등으로 법적 지위가 불안정하게 된다. 따라서 <수리거부>는 처분에 해당하므로 취소소송의 대상이 된다.
- 끝 -	

문2) : 25점	
I. 물음#1	
1. 이의신청의 의의	① 이의신청이란 위법·부당한 행정작용으로 인해 권리가 침해된 자가 처분청에 대하여 그러한 행위의 시정을 구하는 절차를 말한다. ② 강학상 이의신청은 행정불복 중 행정심판이 아닌 것, 달리 말하면 준사법적 절차가 아닌 행정불복을 말한다.
2. 행정심판의 의의	행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분 또는 부작위로 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고 아울러 행정의 적정한 운영을 도모하기 위해 행정기관에 의한 심판절차로서, 사법절차가 준용되는 불복절차를 말한다.
3. 양자의 구별실익	① 행정심판의 성격을 가진 이의신청에는 [행정심판법]이 적용되어, 이를 거친 후에는 다시 행정심판을 청구할 수 없다(행정심판법 제51조). ② 반면, 강학상 이의신청은 이를 거친 후에도 행정심판 청구가 가능

	한 것에 구별실익이 있다(행정기본법 제36조 제3항).
4. 양자의 구별기준	
1) 학설	
(1) 심판기관기준설	행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.
(2) 불복절차기준설	준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.
2) 판례	국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.
3) 검토	헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복

	절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.
II. 물음#2	
1. 쟁점의 정리	국토교통부장관이 부과한 3천만원의 과징금이 이의신청 후 2천만원으로 감액된 경우, 甲이 제기하여야 할 소송의 대상이 무엇인지 검토한다.
2. 과징금의 의의 및 법적성질 (감정평가법 제41조)	① 과징금이란 행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. ② 감정평가사법상 과징금은 계속적인 공적업무수행을 위해 업무정지처분에 갈음하여 부과되는 것으로 <변형된 과징금>에 해당한다. ③ 과징금부과행위는 행정행위로서 급부하명의 성격을 가지며 행정소송의 대상이 되는 <처분>이다.
3. 과징금 부과 이의신청이 강학상 이의신청 여부	감정평가법 제42조 제3항은 과징금 이의신청에 따른 결정에 이의가 있는 자는 [행정심판법]에 따라 행정

심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 이
의신청 후 행정심판을 청구할 수 있는 점에서, 사안
은 <강학상 이의신청>에 해당한다고 볼 수 있다.
4. 갑이 제기하여야 하는 소송의 대상
1) 학설
① 당초처분과 경정처분은 독립된 처분으로 별개의
소송대상이라는 견해(병존설), ② 당초처분은 경정처
분에 흡수되어 소멸하고, 경정처분만이 효력을 가지
고 소송의 대상이 된다는 견해(흡수설), ③ 경정처분
은 당초처분에 흡수되어 경정처분에 의하여 수정된
당초처분이 소송의 대상이 된다는 견해(역흡수설) 등
이 있다.
2) 판례
(1) 감액경정처분의 경우
① 감액경정처분은 당초처분의 전부를 취소한 다음
새로이 처분을 한 것이 아니라, 당초처분의 일부취소
에 불과하므로, 경정처분에 의하여 감액되고 남아 있
는 당초처분이 항고소송의 대상이 된다.(역흡수설) ②
이 경우 제소기간의 준수여부도 당초처분을 기준으
로 판단한다.

(2) 증액경정처분의 경우
① 당초처분은 증액처분에 흡수되어 소멸되므로 증
액경정처분이 항고소송의 대상이 된다.(흡수설) ② 이
경우 제소기간의 준수여부도 증액경정처분을 기준으
로 판단한다.
3) 검토
① 감액경정처분의 경우에는 경정처분에 의하여 수
정된 원처분을 소의 대상으로 하는 것이 원처분의
연속성 측면에서 타당하고, ② 증액경정처분의 경우
에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액경정
처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.
5. 사안의 해결
甲은 과징금이 감액되는 경정처분이 있었으므로, 3천
만원 중 남은 2천만원(변경된 원처분)을 소송의 대상
으로 하는 것이 타당하다.
- 끝 -

문3) : 15점
I. 원처분주의 및 재결주의의 개념
1. 개념
① <원처분주의>란 원처분과 재결 모두 취소소송의
대상이 될 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분취소소
송에서만 주장할 수 있고, 재결취소소송에서는 원처
분의 위법은 주장할 수 없고, 재결 자체의 고유한 위
법만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.
② <재결주의>란 원처분에 대해서는 소송을 제기할
수 없고, 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록
하되, 재결 자체의 위법뿐만 아니라 원처분의 위법도
재결취소소송에서 주장할 수 있도록 하는 제도를 말
한다.
2. 현행법상 태도
행정소송법 제19조는 원처분주의를 택하고 있다.
II. 인용재결에 고유한 위법이 있는 경우
1. 재결 자체의 고유한 위법의 인정범위
1) 재결자체의 고유한 위법의 의미
원처분에는 없고 재결 자체에만 존재하는 위법을 의

미하는 것으로 재결 자체의 주체*내용*절차*형식의
위법이 있는 경우를 말한다.
2) 재결고유의 하자유형
① 주체상 하자로는 위법*부당하게 각하재결, 기각재
결, 인용재결을 한 경우를 말한다. ② 절차상 하자로
는 심판절차를 준수하지 않은 경우, ③ 형식상 하자
로는 서면으로 하지 않거나, 중요 기재사항을 누락한
경우, ④ 내용상 하자는 위법*부당하게 각하재결, 기
각재결, 인용재결을 한 경우를 말한다.
2. 인용재결에 고유한 위법이 있는 경우
1) 제3자효 행정행위에 대한 인용재결인 경우
(1) 문제점
제3자효 행정행위에 대한 행정심판청구의 인용재결
로 인하여 비로소 권리의익을 침해받게 되는 자가
그 인용재결에 대하여 취소를 구할 수 있는지 문제
된다.
(2) 학설
① 제3자효 행정행위에서 인용재결로 권익을 침해당
한 자가 인용재결의 당부를 다투는 것은 재결 자체

의 고유한 하자를 주장하는 것이라는 견해와(행정소송법 제19조 단서설), ② 해당 인용재결은 형식상으로는 재결이나, 실질적으로는 권익을 침해당한 자에 대한 별도의 새로운 처분이므로 인용재결이 최초의 처분이라는 견해가 있다.(행정소송법 제19조 본문설)
(3) 판례
① 대법원은 제3자료를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권익이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다툴 필요가 있고, ② 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다고 판시하였다.
(4) 검토
① 인용재결로 비로소 권익을 침해받게 되는 자는 인용재결을 대상으로 소를 제기할 수 있다. ② 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 이는 재결 고유의 하자를 주장하는 것으로 보는 것이 타당하다.

2) 부적법한 인용재결이 있는 경우
① 행정심판의 제기요건을 결여하였음에도 불구하고 각하하지 아니하고 인용재결을 한 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 해당하므로 제3자는 인용재결을 다툴 수 있다. ② 판례로 자기완결적 신고의 수리는 처분성이 없으므로 수리처분의 취소를 구하는 행정심판청구는 부적법 각하해야 함에도 불구하고 인용재결한 경우에는 인용재결에 고유한 하자가 있으므로 인용재결이 행정소송의 대상이 된다고 보았다.
- 끝 -

문4) : 15점
I. 거부의 의의 및 구별개념
① 거부란 행정청이 국민으로부터 어떤 신청을 받고서 그 신청에 따르는 행위를 하지 않을 뜻을 표시하는 행위를 말한다. ② 거부는 신청에 대한 명백한 거절의 의사표시로서 행정청이 처음부터 아무런 의사표시를 하지 않은 부작위와 구별된다.
II. 거부행위가 처분이 되기 위한 요건
1. 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용일 것 신청의 대상이 된 행위가 행정처분이어야 한다.
2. 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떠한 변동을 일으킬 것 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다.
3. 법규상 또는 조리상의 신청권이 있을 것

행정청의 거부행위가 처분이 되기 위해서는 국민이 행정청에 대하여 그 신청에 따른 행정행위를 해줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다.
4. 신청권 존부에 대한 견해의 대립
1) 문제점 신청에 대한 거부가 처분이 되기 위해서 법규상*조리상 신청권이 필요한지가 문제 된다.
2) 학설 ① 신청권의 존부를 원고적격의 문제로 보는 <원고적격설>, ② 신청권의 존부는 본안에서 판단하여야 한다고 보는 <본안요건설> 및 ③ 단순한 응답을 받을 권리로서 신청권이 필요하다고 보는 <대상적격설>이 있다.
3) 판례 판례는 신청권이란 신청인이 누구인가를 고려하지 않고, 단순한 응답받을 권리를 의미한다고 보았으며, 어떤 개인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 있다면 그 거부행위는 항고소송의 대상인 처분으로 보아야

한다고 판시하여 대상적격설을 취하고 있다.
4) 검토
현행 행정소송법은 신청권에 대응하는 처분의무를 부작위의 요소로 규정하고 있고, 거부처분 개념은 부 작위개념과 연결되어 있으므로 현행 행정소송법에 서는 신청권을 거부처분의 요건으로 보는 것이 타당 하다.
- 끝 -
문 5) : 10점

I. 쟁점의 정리
① 처분청은 직권으로 당초처분을 변경할 수 있다.
② 변경처분이 이루어질 경우, 처분의 상대방은 종전 처분(선행처분)과 후속처분(후행처분) 중 무엇을 대상 으로 행정소송을 제기해야 하는지가 문제된다.
II. 판례
1. 적극적(실질적) 변경처분
① 후속처분이 종전처분의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 경우, 종전처분은 그때부터 효력을 상실하 므로 후속처분만이 항고소송의 대상이 된다. ② 이 경우 변경취소소송의 제소기간의 준수여부는 변경처 분시를 기준으로 한다.
2. 소극적(일부) 변경처분
① 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내 용 중 일부만을 추가*철회*변경하는 것이고 추가*철회 회*변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불 가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하 고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다. ② 만약 선행처분 취소소송에 후행처분 취소청구를 추 가하였다면 후행처분에 관한 제소기간 준수여부는

청구변경 당시를 기준으로 판단하여야 한다.
III. 검토
① 후속 처분이 종전 처분을 실질적으로 변경하는 경우에는 <후속 처분>을 소송의 대상으로 하되, ② 후속 처분이 종전 처분의 유효성을 전제로 그 내용 중 일부만을 추가*철회*변경하는 것이고, 그 추가*철회 회*변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불 가분하지 않은 경우에는 <종전 처분>을 소송의 대상 으로 하는 것이 논리상 타당하다.
- 끝 -

문 6) 10점
I. 임시처분의 의의(행정심판법 제31조)
① 행정청의 처분이나 부작위 때문에 발생할 수 있 는 당사자의 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위해 당사자에게 임시지위를 부여하는 행정심판위원 회의 결정을 말한다. ② 행정심판에서는 의무의행심 판이 인정되기 때문에 임시처분이 가능하다.
II. 요건
1. 적극적 요건
① 심판청구가 계속 중일 것, ② 처분 또는 부작위가 위법*부당하다고 상당히 의심되는 경우일 것, ③ 처 분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위한 것일 것, ④ 이를 막기 위하여 임시지위를 정해야 할 필요가 있어야 한다.
2. 소극적 요건
임시처분이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것을 요건으로 한다.

Ⅲ.	임시처분의 보충성
	임시처분은 집행정지와의 관계에서 보충적 구제제도
	이므로, 임시처분은 집행정지로 목적을 달성할 수 있
	는 경우에는 허용되지 않는다(행정심판법 제31조 제
	3항).
IV.	임시처분의 결정 및 취소
	① 위원회는 직권 및 당사자의 신청에 의하여 임시
	처분을 결정할 수 있다. ② 위원회는 임시처분을 결
	정한 후에 임시처분이 공공복리에 중대한 영향을 미
	치거나 그 처분사유가 없어진 경우에는 직권 또는
	신청에 의하여 임시처분 결정을 취소할 수 있다.
	- 끝 -
	- 이하여백 -

0기 7주차 예시답안

문 1) : 40점 - 0기 법규스터디 7주차
I. 물음 #1
1. 쟁점의 정리
① 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]은 형식은 대통령령 형식이나, 실질은 행정규칙의 성질을 가진다. 이는 <법규명령형식의 행정규칙>인바, 협의소익의 인정여부와 관련하여 그 법적성질을 검토한다. ② 또한 가중처벌 규정이 있는 경우 처분의 효력이 소멸한 후에도 <협의소익>이 인정될 수 있는지 검토한다.
2. 감정평가법 시행령 제29조 별표3의 법적성질
1) 학설
① 규범의 형식을 중시하고 법적 안정성 확보를 위해 법규명령으로 보는 <법규명령설(형식설)>과 ② 규범의 실질을 중시하고 구체적 타당성을 중시하여 행정규칙으로 보는 <행정규칙설(실질설)>, ③ 수권여부를 기준으로 판단하는 견해로서, 상위법령의 수권에 근거하여 제정되었다면 법규명령으로 보고 위임 없이 제정되었다면 행정규칙으로 보는 <수권여부 기준설>이 있다.

2) 판례
① 판례는 <제재적 처분기준>인 경우 부령형식의 행정규칙은 행정규칙으로 보고 있으나, ② 대통령령의 형식으로 규정된 경우 당해 기준을 법규명령으로 보았다. ③ 다만 일부 판례에서는 처분기준을 정액이 아닌 처분의 최고한도액이라고 봄으로써 재량이 행정청에 있다고 판시한 바 있다.(청소년보호법 시행령 과징금부과기준)
3) 검토
① 대통령령과 부령의 형식적 차이에 따라 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 구분하는 것은 합리적인 이유가 없어 타당하지 않다. ② 대통령령과 부령 모두 헌법 제75조 및 제95조에 근거한 형식이며 법규명령으로서 절차적 정당성이 부여되어 있으므로 국민의 예측가능성을 보장하는 측면에서 형식을 기증하여 법규명령으로 보는 <법규명령설>이 타당하다.
3. 협의 소익 인정여부
1) 의의 및 근거

① 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다.
② [행정소송법] 제12조의 해석과 관련하여 다수설과 판례는 전문은 원고적격에 관한 규정이나, 후문은 협의의 소익에 관한 규정으로 본다.
2) 회복되는 법률상 이익의 범위
(1) 논의 실익
[행정소송법] 제12조 제2문의 회복되는 <법률상 이익>의 해석과 관련하여 전문의 법률상 이익과 동일하게 해석할 것인지 아니면 부수적 이익도 포함한다고 보는 것인지 견해가 대립한다.
(2) 학설
① [행정소송법] 제12조 후문의 <법률상 이익>은 취소소송을 통하여 구제되는 기본적인 법률상의 이익뿐만 아니라 <부수적 이익>도 포함한다는 점에서 원고적격에서의 <법률상 이익>보다 넓게 보는 것이 다수견해이다. ② 다만, 이러한 <부수적 이익>에 어디까지 포함될 것인가에 대하여 (ㄱ) 명예*신용의 이익은 포함되지 않는다는 견해, (ㄴ) 명예나 신용의 이익도 경우에 따라서는 포함된다는 견해, (ㄷ) 경제적*정

신적 이익까지 포함된다고 보는 견해가 있다.
(3) 판례
① 판례는 전문과 후문의 <법률상 이익>을 동일하게 보고, <당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 개별적*직접적*구체적 이익>이라고 해석하고, 간접적이거나 사실적*경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 <법률상 이익>에 해당되지 않는다고 본다. ② 다만 최근에는 위법한 처분이 반복될 위험성이 있어 행정처분의 위법성 확인 내지 불분명한 법률문제에 대한 해명이 필요하다고 인정되는 경우에 소의 이익을 긍정하여 소의 이익을 넓히고 있다.
(4) 검토
[행정소송법] 제12조 제2문은 협의의 소익에 대한 근거 조항으로 전문의 법률상 이익과 후문의 회복되는 법률상 이익을 일치시킬 필요가 없으며, 국민의 권리구제 확대를 위해 전문의 법률상 이익보다 넓게 보아, 명예 신용 등 인격적 이익도 포함된다고 보는 것이 타당하다.
3) 처분효력 소멸시 협의소익 인정여부

(1) 소의 이익이 인정되지 않는 경우
① 처분의 효력이 소멸한 경우, ② 원상회복이 불가능한 경우, ③ 처분 후의 사정변경에 의해 이익침해가 해소된 경우, ④ 보다 실효적인 구제수단이 있는 경우에는 소의 이익이 부정된다.
(2) 가중처벌 규정이 있는 경우
① 가중요건이 법령으로 규정되어 있는 경우 가중요건 등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 제재처분의 취소를 구할 협의의 소익이 인정된다.
② 가중요건이 부령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우 (ㄱ) 부정설로는 부령형식의 행정규칙은 행정규칙에 불과하여 행정청에 대해 법적 구속력을 미치지 않으므로 소의 이익을 부정하는 견해(변경전 판례의 견해)가 있다. (ㄴ) 긍정설로는 (a) 부령형식의 행정규칙을 행정규칙으로 보면서도 소의 이익을 인정하는 견해, (b) 부령형식의 행정규칙의 법규성 여부를 묻지 않고 소의 이익을 인정하는 견해(대법원 다수견해),

(c) 부령형식의 행정규칙을 법규명령으로 보면서 소의 이익을 인정하는 견해(대법원 별개의견) 등이 있다.
③ 가중요건이 행정규칙으로 규정되어 있는 경우 담당 공무원은 행정규칙도 준수하여야 하므로 가중요건이 행정규칙에 규정된 경우에도, 취소소송을 통해 장래의 불이익을 제거할 현실적 필요성이 있다고 보는 것이 타당하다. 최근 판례도 같은 입장이다.
④ 판례 (ㄱ) 종래에는 가중요건이 법률이나 대통령령에 규정되어 있는 경우에는 소의 이익을 긍정한 반면, 부령형식에 규정된 제재적 처분기준을 행정규칙에 불과한 것으로 보아 소의 이익을 부정했었다. (ㄴ) 그러나 최근 대법원은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제요건을 규정하고 있다면, 그 기준의 법적성질에 상관없이 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 긍정하는 입장이다.

⑤ 검토
(ㄱ) 가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 법률이나 법규명령에 규정된 경우 뿐만 아니라 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다. (ㄴ) 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익을 인정하는 것이 타당하다.
4. 사안의 해결 2개월의 업무정지처분은 경과하였으나, [별표3]은 가중처분을 규정하고 있으므로 甲은 동 규정의 법적 성질 여부와 무관하게 가중처분을 받을 위험이 있다. 따라서 협의소익이 인정되므로 갑은 취소소송을 계속할 이익이 인정된다.
II. 물음#2
1. 쟁점의 정리 갑이 업무정지 처분에 대해 집행정지를 신청한 경우, 그 인용 가능성에 대해 검토한다.

2. 업무정지처분의 의의 및 법적성질 업무정지처분은 국토교통부장관이 감정평가법인등에게 감정평가업을 하지 못하게 하는 부작위 하명으로 <처분>이다.
3. 집행부정지 원칙 및 집행정지(행정소송법 제23조) ① 행정소송법 제23조 제1항은 집행부정지를 원칙으로 규정하고 있다. ② 소송이 길어지면 승소판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다. ③ 따라서 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다.
4. 집행정지의 요건
1) 적극적 요건 (1) 적법한 본안소송의 계속 ① 민사소송법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다. ② 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

(2) 처분 등의 존재
① 집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다. ② 따라서 부작위에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다.
(3) 회복하기 어려운 손해발생의 우려
회복하기 어려운 손해란 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 금전보상이 불능인 경우 뿐만 아니라 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜 수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유·무형의 손해를 말한다.
(4) 긴급한 필요
① <긴급한 필요>란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다. ② 판례는 긴급한 필요가 있는지 여부는 처분의 성질, 양태와 내용, 처분상대방이 입는 손해의 성질·내용과 정도, 원상회복·금전배상의 방법과 난이도 등은 물론 본안청구의 승소가능성 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 보았다.

2) 소극적 요건
(1) 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것
행정소송법 제23조 제3항에 의거 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다.
(2) 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것
① 행정소송법상 명문으로 규정된 요건은 아니지만 <본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것>이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다.
② 이에 대해 본안에서 승소가능성이 전혀 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 취지에 반하며, 집행정지신청의 남용을 방지할 필요도 있으므로 본 요건이 요구된다고 보는 것이 일반적 견해이다.
5. 사안의 해결
① 적법한 본안 소송이 계속중이고, ② 업무정지는 <처분>에 해당하며, ③ 甲은 업무정지로 인해 명예가 실추되었으며, 이로 인한 고객이탈등은 금전적으로 보상할 수 없는 <회복하기 어려운 손해>에 해당한다. ④ 이러한 회복하기 어려운 손해는 원상회복이

어려운 바 <본안판결을 기다릴 여유가 없다.> ⑤ 업무정지로 인한 감정평가업계의 질서등 공공복리에 영향을 줄 우려가 없으며 ⑥ 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않은 바 <모든 조건>을 충족하고 있다. 따라서, 甲이 신청한 집행정지는 인용될 것이다.
- 끝 -

문2) : 25점
I. 쟁점의 정리
국토교통부장관이 소송이 진행되는 중에 처분 사유를 추가·변경할 수 있는지 여부를 검토한다.
II. 처분사유 추가 변경 의의 및 취지 등
① 처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상 근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다. ② 처분사유의 추가·변경은 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위해 그 취지가 인정되며, 원고의 방어권 보장과 이유제시제도의 취지를 고려하여 일정한 한계 내에서 이루어진다. ③ 행정소송법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 인정되며, 대법원규칙(법규명령)에 규정되어 있다.
III. 구별개념
① 처분사유의 추가·변경은 처분의 동일성(소송물)을 전제로 하므로 처분변경으로 인한 소의 변경(행정소송법 제22조)과도 다르다. ② 처분사유의 추가·변경은 처분시에 이유제시가 되었으나 소송계속 중에 처

문3) : 20점	
I. 법률상 이익의 의미	
1. 원고적격의 의미	원고적격이란 원고로서 소송을 수행하여 본안판결을 받을 수 있는 자격을 말한다.
2. 법률상 이익의 의미	
1) 관련규정	① 「행정소송법」 제12조에서 원고적격과 관련하여 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있다. ② 따라서 법률상 이익이 무엇을 의미하는지 문제된다.
2) 학설	① 위법한 처분으로 권리를 침해당한 자만이 원고적격을 갖는다는 <권리구제설>, ② 위법한 처분으로 인하여 근거법규 및 관계법규에 의하여 보호되는 이익이 침해된 자에게 당해 처분을 취소할 원고적격이 인정된다고 보는 <법률상 보호이익구제설>(통설*판례), ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 실질적으로 재판상 보호할 가치가 있는 이익이

침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치이익구제설>, ④ 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성보장설> 등이 있다.	
3) 판례	법률상 보호되는 이익이라 함은 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적*직접적*구체적 이익을 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적*간접적*추상적 이익과 같이 사실적*경제적 이해관계를 갖는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않는다고 판시하고 있다.
4) 검토	① 권리구제설은 원고적격의 인정 범위가 너무 좁고 ② 보호가치이익구제설은 보호가치 판단기준이 모호한 점 ③ 적법성보장설은 취소소송을 객관화하는 문제점이 있다. ④ 따라서 국민의 권익구제 및 남소방지 등 관점에서 <법률상 보호이익구제설>이 타당하다.

3. 법률의 범위	① 당해 처분의 근거법규에 한정된다는 견해와 ② 근거법규 외에 관계법규에 의해 보호되는 이익도 포함된다는 견해, ③ 헌법상의 기본권까지 포함된다는 견해가 있다. ④ <판례>는 법률상 이익이란 근거법규 및 관계법규에 의해 보호되는 이익이라고 하면서도, 그 인정범위를 넓혀 가는 경향에 있다.
II. 인인소송	
1. 의의	어떠한 시설의 설치를 허가하는 처분 등에 대하여 당해 시설의 인근주민이 다투는 소송을 말한다.
2. 판례	당해 처분의 근거법규 및 관계법규가 공익 뿐만 아니라 인근주민의 개인적 이익도 보호하고 있다고 해석되는 경우에는 인근주민에게 원고적격이 인정된다고 판시하였다.
3. 환경영향평가법령과 원고적격 인정기준	
1) 환경영향평가 대상지역 안의 주민의 원고적격	환경영향평가 대상지역 안의 주민이 갖는 환경상의

이익은 직접적*구체적 이익으로서 그들에 대한 특단의 사정이 없는 한 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정된다.	
2) 환경영향평가 대상지역 밖의 주민의 원고적격	환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라고 할지라도 처분 등으로 인하여 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 원고적격을 인정받을 수 있다고 판시한 바 있다.
- 끝 -	

0기 8주차 예시답안

문 1) : 40점 - 0기 법규스터디 8주차 예시답안	
I. 물음#1	
1. 의의 및 유형	
① 행정상 손해배상이란 공무원의 고의*과실로 인한 위법한 직무행위 또는 영조물의 하자로 인하여 발생 한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배 상을 해주는 제도를 말한다. ② 행정상 손해배상은 국가배상이라고도 하며, 국가배상법에서는 국가배상 책임의 유형으로 (ㄱ) 공무원의 위법행위로 인한 배 상책임(국가배상법 제2조)과 (ㄴ) 영조물의 설치*관리 상의 하자로 인한 배상책임(동법 제5조)을 규정하고 있다.	
2. 법적성질	
1) 국가배상청구권의 법적성질	
(1) 학설	
국가배상책임의 법적 성격에 대해 (ㄱ) 국가배상책임 은 일반불법행위 책임의 한 유형에 불과한 것으로서, 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 <사권설>과 (ㄴ) 국가배상책임은 공법적 원인에 의해 발생한 것 이므로 공권으로 보는 <공권설>이 대립한다.	

(2) 판례	
판례는 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 입장 이다.	
(3) 검토	
생각건대, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발 생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으 로 보고, 국가배상청구권의 법적 성격은 공권으로 보 는 것이 타당하다.	
2) 국가배상책임의 법적성질	
(1) 문제점	
[국가배상법] 제2조에서 직접적인 가해자는 공무원임 에도 불구하고 피해자에 대한 배상책임은 국가 또는 지방자치단체가 부담하는 이유와 관련하여 국가배상 책임의 법적성질에 대하여 대립이 있다.	
(2) 학설	
① 위법한 공무원의 행위는 국가등의 행위로 볼 수 없으므로, 공무원 자신이 배상책임을 져야 하나, 피 해자 구제를 위하여 국가가 대신하여 책임을 지는	

것으로 보는 <대위책임설>, ② 공무원의 행위의 효 과는 국가등의 행위로 귀속되므로 배상책임은 국가 등의 자기책임이라고 보는 <자기책임설>, ③ 공무원 의 위법행위가 경과실인 경우에는 공무원의 행위는 국가 행위이므로 국가가 자기책임으로서 배상책임을 지지만, 고의 또는 중과실에 의한 것일 때에는 기관 의 행위로서 품격을 상실하므로 원칙적으로 공무원 개인의 책임이나, 피해자 구제를 위해 국가가 대신하 여 책임지는 것이라고 보는 <절충설>이 있다.	
(3) 판례	
판례는 경과실의 경우에는 자기책임으로 보고, 고의* 중과실인 경우에는 대위책임이라고 보아 <절충설>의 입장이다.	
(4) 검토	
① 위법행위가 공무원의 고의 또는 중과실에 기한 경우에 그 행위는 기관행위로서 품격을 상실하게 된 다. ② 그러나 그 행위의 외관이 여전히 공무원의 직 무행위로 보여진다면 피해자와의 관계에서는 기관의 행위로 인정하여야 하며, 피해자인 국민을 두텁게 보 호하기 위해 국가가 자기책임으로 배상하는 것이 타	

당하다.	
II. 물음#2	
1. 문제점	
헌법 제29조 제1항 단서는 공무원 개인의 책임은 면 제되지 않는다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 국 가배상책임에서 가해 공무원 개인도 피해자에 대해 서 배상책임을 지는지가 문제 된다.	
2. 학설	
① 국가배상책임을 자기책임으로 보는 입장에서 국 가와 공무원 개인의 책임은 독립해서 성립되고, 피해 자의 권리구제를 폭넓게 보장하기 위하여 선택적 청 구권 행사를 긍정하는 <긍정설>, ② 국가배상책임을 대위책임으로 보는 입장에서 공무원의 직접책임을 인정하는 것은 공무원의 직무집행을 위축시킬 우려 가 있으므로 선택적 청구권 행사를 부정하는 <부정 설>, ③ 경과실에 기한 것인 경우는 여전히 기관행 위이므로 국가만이 책임을 지고, 고의*중과실인 경우 에는 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권 을 긍정하는 <제한적 긍정설>이 있다.	

3. 판례	전원합의체 판례의 다수의견은 경과실의 경우에는 부정하고, 고의*중과실의 경우에는 공무원 개인의 책임을 긍정하여 절충설의 입장이다.
4. 검토	① 헌법 제29조 제1항 단서에서 공무원의 책임이 면제되지 않는다고 규정하고 있으나 구체적인 손해배상책임의 범위까지 규정하고 있지는 않고, 국가배상법은 공무원의 내부적 책임만 규정하고 있을 뿐 외부적 책임에 대해서는 규정한 바 없다. ② 따라서 양자를 조화롭게 해석하고 공무원의 직무집행행위를 위촉시키지 않기 위해서 고의*중과실의 경우에만 공무원 개인의 책임을 인정하는 <제한적 긍정설>이 타당하다.
5. 공무원의 구상책임	① 국가나 지방자치단체가 국가배상책임을 지는 경우에 공무원에게 고의 또는 중과실이 있으면 국가나 지방자치단체는 공무원에게 구상할 수 있다. ② 경과실의 경우 공무원의 사기저하와 사무정체를 방지하기 위해 정책적 고려에서 구상을 인정하지 않고 있

다.	
Ⅲ. 물음#3	
1. 공무원	① 국가배상법 제2조의 <공무원>은 행정부, 입법부, 사법부 소속의 공무원 및 지방자치단체의 공무원을 포함하며, 실질적으로 공무를 수행하는 <기능적 의미의 공무원>을 말한다. ② 판례는 공무를 위탁받은 사인인 공무수탁사인의 경우 공무의 위탁이 일시적이고 한정적인 경우에도 공무원에 해당한다고 판시한 바 있다.
2. 직무행위	직무행위의 범위에 대해 견해 대립이 있으나, 판례는 국가배상청구의 요건인 <공무원의 직무>에는 권력적 작용만이 아니라 비권력적 작용도 포함되며 단지 행정주체가 사경제주체로서 하는 활동만 제외된다고 하여 광의설의 입장을 취한다.
3. 직무를 집행하면서 행한 행위(직무 관련성)	① 직무를 <집행하면서>는 단순한 직무 집행행위뿐만 아니라 널리 외형상 직무집행과 관련 있는 행위

를 포함한다고 보는 것이 통설*판례의 태도이다(외형설). ② 즉, 비록 실질적으로 직무행위가 아니거나 주관적으로 공무집행 의사가 없다고 하더라도 외관상 공무원의 집행행위로 보여진다면 <직무를 집행하면서>에 포함되는 것으로 보아야 한다.	
4. 고의 또는 과실	
1) 과실책임주의	① (ㄱ) 고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고, (ㄴ)과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태 하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 의미한다. ② 과실에는 중과실과 경과실을 모두 포함한다.
2) 과실의 객관화 경향	① [국가배상법]상 과실을 행위자의 주관적 심리상태로 보는 것이 아니라, <당해 직무를 담당하는 평균적 공무원의 주의의무>를 기준으로 과실을 판단한다. ② 가해공무원의 특징이 필수적인 것은 아니며, 고의*과실의 입증책임은 원고가 부담한다.
3) 구체적인 검토	

(1) 법령의 해석 및 적용	① 판례는 원칙적으로 공무원이 관계 법규를 알지 못하거나 필요한 지식을 갖추지 못해 법규의 해석을 그르친 경우에는 과실이 있다고 본다. ② 그러나 법령에 대한 해석이 명백하지 않은 등의 이유로 관계 공무원이 그 나름대로 신중을 다하여 합리적인 근거를 찾아 그 중 어느 한 견해를 따라 내린 해석이 후에 대법원의 입장과 달라 결과적으로 위법하게 된 경우까지 공무원의 과실을 인정할 수는 없다고 판시한 바 있다.
(2) 처분의 근거 법령의 위헌*위법선언과 공무원의 과실	① 처분의 근거가 된 법규가 나중에 위헌 또는 위법으로 된 경우에는 공무원에게 일반적으로 과실이 있다고 보기 어렵다. ② 왜냐하면, 공무원에게는 법률의 위헌여부를 심사할 권한이 없어서 명백한 무효가 아니라면 공무원으로서 법규를 적용할 수밖에 없기 때문이다.
(3) 행정규칙에 따른 처분	행정규칙에 정해진 기준에 따른 처분이 나중에 위법한 처분임이 판명되어 취소되었다고 하더라도, 당해

	공무원에게 직무상의 과실이 있다고 할 수 없다.
5. 법령의 위반	
1) 문제점	국가배상책임의 요건이 되는 <법령위반>을 어떻게 이해할 것인지에 대하여 견해의 대립이 있다.
2) 학설	
	① 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법과 동일하게 보아 행위 자체의 법령위반으로 파악하는 <협의의 행위위법설>, ② 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법보다 넓게 보아 법령 위반 뿐만 아니라 널리 인권존중, 공서양속, 신의성실의 원칙의 위반 등도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>, ③ 행위 자체의 위법뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여 행위가 객관적으로 정당성을 결여하였는지 여부로 판단해야 한다고 보는 <상대적 위법성설>, ④ 취소소송의 위법성과는 달리 피해의 결과에 따라 위법성을 판단하여, 손해가 수인한도를 넘으면 위법행위가 된다고 보는 <결과불법설> 등이 있다.

3) 판례	
	① 판례는 공무원의 직무집행이 법령이 정한 요건과 절차에 따라 이루어진 것이라면 특별한 사정이 없는 한 법령에 적합한 것이고, 그 과정에서 개인의 권리가 침해된다고 하여 법령적합성이 곧바로 부정되는 것은 아니라고 하여 결과불법설은 배척하고 행위위법성설에 입각한 판시도 한 바 있으며
	② 최근 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위의 태양 및 원인, 손해의 정도 등 제반사정을 종합하여 객관적 정당성을 상실하였는지 여부를 기준으로 판단하여 상대적 위법성설을 따르는 듯한 판례도 있다.
4) 검토	
	국가배상법이 법치주의의 요청에 따라 법규범을 위반한 직무행위에 의하여 발생된 손해에 대한 국가 등의 배상책임임을 인정하기 위하여 제정되었음을 볼 때, 기본적으로 행위위법설이 타당하다.
	손해전보를 목적으로 하는 국가배상에서 반드시 항고소송의 위법과 동일하게 볼 필요는 없으며, 인권보장의 측면에서 볼 때, 공무원에게 직무상의 일반적 손해방지의무를 인정하는 것이 타당하므로 행위위법설 중에서도 광의의 행위위법설이 타당하다.

6. 손해 및 인과관계	
	① 국가배상책임이 인정되기 위해서는 공무원의 불법행위로 인해 손해가 발생 되어야 한다.
	② <손해>는 가해행위로 인해 발생한 일체의 손해로서 법률상 이익의 침해를 말하며, 반사적 이익의 침해는 해당되지 않는다.
	③ 손해는 적극적*소극적 손해를 불문하고, 생명*신체*정신상의 손해도 포함된다.
	④ 또한, 가해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데, <상당인과관계>의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
IV. 물음#4	
1. 문제점	
	① 취소소송의 확정판결이 난 후, 국가배상청구소송을 제기했을 때 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 여부가 문제된다. ② 이는 취소소송에 있어서 위법과 국가배상청구소송에 있어서 위법

	이 동일한가 하는 문제와 관련이 있다.
2. 학설	
	① 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 동일한 개념이라고 보아 취소소송의 확정판결의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <기판력 긍정설, 협의의 행위위법설>, ② 국가배상청구소송의 위법의 범위가 취소소송의 위법보다 넓다고 보아 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치나, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 보는 <제한적 긍정설, 광의의 행위위법설>, ③ 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 다른 개념으로 보고, 양자의 소송물이 달라 기판력이 미치지 않는다고 보는 <기판력 부정설, 결과불법설*상대적위법성설>
3. 판례	
	판례는 어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없다고 보아, 이에 대한 판례의 입장은 명확하지 않다.

효가 된다. ③ 다만, 취소된 처분의 취소사유와 기본적인 사실관계의 동일성이 없는 다른 처분사유를 들어 동일한 내용의 처분을 하여도 이는 동일한 처분이 아니므로 기속력에 반하지 않는다. ④ 또한, 판례는 절차나 형식의 위법을 이유로 처분등이 취소되는 판결이 확정된 경우에는 행정청이 판결에 적시된 절차나 형식의 위법사유를 보완하여 다시 새로운 처분을 하더라도 이는 기속력에 저촉되지 않는다고 본다.
2) 재처분의무 (「행정소송법」 제30조 제2항)
① 행정소송법 제30조 제2항에 의거 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. ② 재처분의무는 판결의 취지를 존중하면 되는 것이므로 반드시 원고가 신청한 내용대로 재처분을 해야 하는 것은 아니다. ③ 재처분의무는 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다(동조 제3항).
3) 결과제거의무 (원상회복의무)
① 취소판결이 확정되면 행정청은 취소된 처분으로

인해 초래된 위법상태를 제거해야 할 결과제거의무(원상회복의무)를 진다. ② 결과제거의무에 대한 명문의 규정은 없지만 일반적으로 행정소송법 제30조 제1항의 해석상 인정된다고 본다.
II. 물음#2
1. 간접강제의 의의 및 취지(행정소송법 제34조)
① 간접강제란 행정청이 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 법원이 일정한 절차에 따라 행정청에게 배상을 명하는 제도를 말한다. ② 간접강제는 판결의 실효성 확보에 그 취지가 인정된다.
2. 요건
① 간접강제의 요건으로는 (ㄱ) 거부처분에 대한 취소판결이 확정될 것과 (ㄴ) 처분청이 거부처분취소판결의 취지에 따른 재처분을 하지 않을 것이 있다.
② 여기에서 <재처분을 하지 않은 것>에는 아무런 재처분을 하지 않은 것뿐만 아니라, 재처분이 기속력에 반하여 당연무효가 된 것도 포함된다.
3. 절차

① 간접강제는 (ㄱ) 당사자가 제1심 수소법원에 간접강제를 신청하고, (ㄴ) 법원은 간접강제의 신청이 이유 있다고 인정함으로써 간접강제결정을 한다.
② 간접강제결정으로써 법원은 상당 기간을 정하고 그 기간 내에 이행하지 아니하면 지연기간에 따라 일정한 배상을 명하거나, 즉시 손해배상 할 것을 명할 수 있다.
4. 배상금의 성질 (심리적 강제수단)
① 판례는 간접강제는 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서 재처분 지연에 대한 제재나 손해배상은 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것이라고 보았다. ② 따라서 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에라도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다고 본다.
5. 적용범위 (무효등확인판결)
1) 문제점
무효등확인판결의 경우 간접강제를 준용하는 규정이 없어 간접강제가 적용될 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설
① 간접강제를 준용하는 규정이 없으므로 부정하는 <부정설>, ② 행정소송법 제34조 제1항에서 <제30조 제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니하는 때>라고 규정하고 있음을 근거로 거부처분이 당연무효인 경우에도 간접강제가 허용된다고 보는 <긍정설>이 있다.
3) 판례
판례는 무효등확인판결이 간접강제를 준용하지 않으므로 부정하는 입장에 있다.
4) 검토
무효등확인소송에서도 행정청의 재처분의무 위반에 대한 실효성 확보를 위해 간접강제가 적용될 수 있다고 보는 것이 타당하다.
- 끝 -

